

## 제14장

---

# 민사소송법상의 담보

- 
- 제1절 총 설 594
  - 제2절 소송비용의 담보제공의무 595
  - 제3절 담보제공을 명하는 재판 599
  - 제4절 담보제공의 절차 606
  - 제5절 담보권의 실행 608
  - 제6절 담보의 취소 611
  - 제7절 담보물변경 621

## 제1절 총 설

‘민사소송법상의 담보’란 당사자의 소송행위 또는 법원이 한 처분에 의하여 상대방에게 생길지 모를 손해의 배상을 미리 확보하기 위한 소송상의 수단이다. 민사소송법상의 담보에는 소송비용의 담보, 가집행의 담보 및 집행정지의 담보가 있다.

‘소송비용의 담보’란 원고가 소를 제기하는 경우 그 패소시에 피고의 소송비용액 상환청구권의 이행을 확보하기 위하여 피고의 신청이나 직권으로 법원이 제공을 명하는 담보를 말한다(민소 117조).

‘가집행선고의 담보’는 가집행선고 있는 판결의 집행이 실시되는 경우에도 나중에 가집행선고가 취소 또는 변경되는 것을 예상하여 채무자가 입게 되는 손해를 담보하는 것을 말하고(민소 213조 1항), ‘가집행 면제 선고의 담보’는 가집행을 하지 못함으로 인하여 승소채권자가 입게 되는 일체의 손해를 담보하는 것이다(2항).

‘집행정지의 담보’는 가집행의 선고가 붙은 판결에 대하여 상소를 하거나, 정기금의 지급을 명한 확정판결에 대하여 정기금 액수의 변경을 구하는 소를 제기하면서 강제집행의 일시 정지를 구하여 오는 경우, 재심 또는 상소의 추후 보완신청을 하면서 강제집행의 일시 정지를 구하여 오는 경우에 제공을 명하는 담보이다(민소 500조, 501조).

민사소송법은 총칙편에 소송비용의 담보에 관하여 상세히 규정하면서(민소 117조 내지 126조), 가집행의 담보, 집행정지의 담보에 관하여도 위 규정 일부를 준용하는 체제를 취하고 있다(214조, 502조 3항). 실무상 위 규정은 소송비용의 담보의 경우보다도 오히려 가집행 또는 강제집행 절차상의 담보에서 준용되는 예가 훨씬 많고, 담보제공의 방식(122조), 담보권행사의 방법(123조), 담보의 취소(125조), 담보물의 변경(126조) 등의 절차는 다른 법률에

다른 소제기에 관하여 제공되는 담보에 관하여도 준용되고 있다(127조).

## 제2절 소송비용의 담보제공의무

### 1. 담보제공을 명하여야 할 경우

원고가 대한민국에 주소·사무소와 영업소를 두지 아니한 때, 소장·준비서면, 그 밖의 소송기록에 의하여 청구가 이유 없음이 명백한 때 등 소송비용에 대한 담보제공이 필요하다고 판단되는 경우 또는 담보가 부족한 경우에는 법원은 피고의 신청이나 직권으로 원고에게 소송비용에 대한 담보를 제공하도록 명하여야 한다(민소 117조 1항, 2항). 원고가 대한민국에 주소 등을 두고 있지 아니하여 피고가 승소하더라도 소송비용을 상환받기 어려울 것으로 예상되거나 소송기록에 의하여 청구가 이유 없음이 명백하여 원고가 소송비용을 부담하게 될 것이 분명하다는 등의 사유가 있는 경우에 피고의 원고에 대한 소송비용상환청구권의 용이한 실현을 미리 확보하여 두려는 것이다. 따라서 소송비용에 대한 담보제공명령은 원고가 대한민국에 주소 등을 두지 아니한 때 또는 소송기록에 의하여 청구가 이유 없음이 명백한 때에 해당하거나 그 밖에 이에 준하는 사유가 있어 피고의 이익을 보호하기 위하여 소송비용상환청구권의 용이한 실현을 미리 확보하여 둘 필요가 있는 경우에만 허용된다(대법원 2013. 5. 31. 자 2013마488 결정). 원고의 국적은 묻지 않는다.

원고의 보조참가인도 참가로 인하여 생길 비용에 관하여는 원고와 마찬가지로 취급한다. 원고와 같은 지위에 있게 되는 독립당사자참가, 원고 측 공동소송참가, 원고 측 승제참가의 경우에도 참가인에게 소송비용에 관한 담보제공의무가 있다. 피고가 반소원고로 되는 경우에도 반소로 생길 소송비용에 관하여 담보제공의무가 있지만, 상소를 제기한 사람은 민사소송법 117

조에 규정된 ‘원고’에 해당하지 않으므로 소송비용에 관한 담보제공의무가 없다.

소송비용의 담보제공의무는 원칙적으로 판결절차에 적용되는 것이고 결정절차에는 적용이 없다. 결정절차에서는 담보제공의 신청을 할 기회가 없는 경우가 많고 가령 임의적 변론이나 심문 등이 있다고 하더라도 심리가 단시간 안에 끝나는 것이 보통이며 담보를 요구할 만큼 비용을 들일 일도 없기 때문이다. 그러나 예외적으로 보전절차에서도 변론이나 심문을 거쳐 장시간 심리하거나, 감정 등이 필요하여 상당한 소송비용이 소요되리라고 예상되는 사건과 같은 경우에는 보전처분의 신청인에게 소송비용의 담보제공의무가 있다고 보아야 할 것이다.

‘소장·준비서면, 그 밖의 소송기록에 의하여 청구가 이유 없음이 명백한 때’란 특정인에 대한 개인적 원한에 의하여 계속적·반복적으로 상대방을 괴롭히기 위한 목적으로 소송을 제기하는 경우, 공무를 수행하는 국가공무원(법원, 행정부 등 포함) 기타 국가기관에 대하여 업무처리나 직무수행에 불만이 있다는 이유로 특별한 법률적 근거 없이 민원성 직무관련 손해배상청구 소송을 제기하는 경우, 승소 목적보다는 상대방에 대한 심리적 압박을 가하는 수단으로 소송을 제기하는 경우 및 원고 주장 자체에 이유가 없으면서 소송비용 회수의 가능성이 희박한 경우 등이 이에 해당한다. 다만 준비명령에서 정한 기한 내에 피고의 답변서에 대한 반박 준비서면을 제출하지 않았다는 사정은 소송기록에 의하여 청구가 이유 없음이 명백한 때에 준하는 사유에 해당한다고 볼 수 없다(대법원 2013. 5. 31. 자 2013마488 결정 참조).

‘담보가 부족한 경우’라 함은 상소의 제기나 소의 확장 등으로 소송비용이 추가로 소요될 것이 예상되는 경우 등 소송의 진행과정에서 제공된 담보가 충분하지 않게 된 경우를 말하고, 담보가 부족한지 여부는 지출한 소송비용의 총액과 담보액을 대비하여 정할 것이고, 전자가 후자를 초과할 때에 피고가 담보의 부족이 생긴 것을 안 것으로 추정한다(대법원 1996. 5. 9. 자 96마



299 결정).

청구의 일부에 대하여 다툼이 없는 경우에는 그 액수가 담보로 충분하면 담보제공을 명할 수 없다(민소 117조 3항). '다툼이 없는 경우'에는 피고가 변론준비기일 또는 변론에서 청구의 일부에 대하여 인낙하는 경우뿐만 아니라 청구원인사실을 자백한 경우도 포함되지만, 재판 외에서 한 자백은 이에 해당하지 않는다. 청구의 일부에 대하여 다툼이 없어야 하고 그 액수가 담보로 충분하여야 하므로 원고의 청구는 금전채권에 한하고, 또한 상계에 의하여 피고가 취득할 수 있는 소송비용상환청구권을 만족시킬 수 있어야 한다. 비재산권상의 청구나 재산상의 청구라도 금전채권이 아닌 것은 이에 해당하지 않는다.

## 2. 피고의 신청 또는 직권에 의한 결정

소송비용담보제도는 피고의 이익을 보호하기 위한 것이므로 이익을 향수할 피고에게 담보제공의 신청권을 인정하고 있다. 피고는 내국인일 필요가 없고, 주소·사무소·영업소를 우리나라에 둘 필요도 없다(대법원 1999. 5. 4. 자 99마633 결정). 소송비용의 담보제공 신청권은 피고에게 있을 뿐 원고가 담보제공 신청을 할 수는 없고, 이는 상소심 절차에서도 동일하게 적용되므로, 원고가 본안소송의 항소심에서 승소하여 피고가 그에 대한 상고를 제기함에 따라 원고가 피상고인으로 되었다고 하여 원고에게 소송비용 담보제공 신청권이 인정되는 것은 아니다(대법원 2017. 9. 14. 자 2017카담507 결정).

담보제공 신청은 서면이나 말로 할 수 있다(민소 161조 1항). 피고의 담보제공 신청은 원고가 상소를 제기하거나 소의 확장적 변경을 하는 등 새로이 담보제공의 원인이 발생한 경우와 같이 특별한 경우를 제외하고는 제1심 본안의 변론 전에 주장하여야 한다. 담보를 제공할 사유가 있음을 알고도 피고가 본안에 관하여 변론을 하거나 변론준비기일에서 진술한 경우에는 담보제공을 신청하지 못한다(118조).

피고가 담보제공 신청권을 상실하면 그 상실의 효과는 제1심만이 아니라 소송이 계속되어 있는 상급심에까지 미치므로 항소심에서 한 피고의 담보제공 신청은 원칙적으로 부적법하다(대법원 2008. 5. 30. 자 2008마568 결정). 상소심에서의 소송비용 담보제공 신청은 담보제공의 원인이 이미 제1심 또는 항소심에서 발생되어 있었음에도 신청인이 과실 없이 담보제공을 신청할 수 없었거나 상소심에서 새로이 담보제공의 원인이 발생한 경우에 한하여 가능하다(대법원 2015. 11. 18. 자 2015카담58 결정). 따라서 담보제공의 원인이 이미 제1심에서 발생되어 있었음에도 불구하고 항소심에서 피고가 담보제공을 신청하기 위해서는 제1심에서 과실 없이 담보제공을 신청할 수 없었다는 것을 소명하여야 할 것이고, 새로이 담보제공의 원인이 발생한 경우에는 심급에 관계없이 상소심(상고심 포함)에서도 그러한 점을 소명하여 담보제공을 신청할 수 있다(대법원 2025. 7. 3. 자 2025마5518 결정). 새로이 담보제공의 원인이 발생한 경우는 예를 들어 피고가 제1심에서는 원고의 청구가 이유 없음이 명백하다는 것을 알지 못하다가 제1심판결 이후에 비로소 이를 알았다고 볼 수 있는 경우, 피고가 항소심에서 이르러서야 소송대리인을 선임하여 소송비용이 추가로 소요될 것이 예상되는 경우 등이 있다(대법원 2017. 4. 21. 자 2017마63 결정). 또한 원고가 제1심의 소송비용 담보제공결정에 따라 그 금액을 공탁한 다음 제1심에서 패소한 후 항소를 제기한 경우에 피고는 원고가 제공한 담보가 부족하다는 이유로 항소심에서 다시 담보제공 신청을 할 수 있다(대법원 1996. 5. 9. 자 96마299 결정).

반면 피고가 적법한 담보제공 신청을 한 경우에는 그 후 응소를 거부하지 않고 본안에 관하여 변론 등을 하였더라도 이미 이루어진 담보제공 신청의 효력이 상실되거나 그 신청이 부적법하게 되는 것은 아니다(대법원 2018. 6. 1. 자 2018마5162 결정).

담보제공을 신청한 피고는 송달료 2회분의 예납과 함께 신청서에는 1,000원의 인지를 첨부하여야 하고(인지 9조 5항 4호, 인지액·편철방법예규),

법원사무관등은 위와 같이 작성된 신청서가 접수되면 민사신청사건으로 전산입력하고 사건부호(‘카담’), 사건번호와 사건명(‘소송비용담보제공’)을 부여하고 기록을 편성한 다음 본안기록에 첨철(별책연결)한다.

담보제공을 신청한 피고는 원고가 담보를 제공할 때까지 소송에 응하지 아니할 수 있다(민소 119조). 소송에 응할지는 피고에게 주어진 권리이므로 응소하면 그 권리가 소멸하지만, 응소하지 않을 경우 담보제공의 신청에 대한 심리를 제외하고 본안에 대한 변론 또는 변론준비절차에서의 진술을 거부할 수 있고 법원으로서도 더 이상 소송을 진행할 수 없다.

피고의 신청 외에도 법원은 직권으로 원고에게 소송비용의 담보를 제공하도록 명할 수 있다. 이는 부당소송을 억제하기 위하여 법원이 직권으로 담보제공을 명할 수 있도록 하는 한편, 주소 등의 기재가 없는 경우에도 법원의 판단에 의하여 피고를 보호할 필요가 있음을 참작하여 직권에 의하여 담보제공결정을 할 수 있도록 한 것이다. 다만 청구가 이유 없음이 명백함을 이유로 담보제공을 명하게 되면 원고 패소라는 예단이 노출되고, 이로 인한 불복 등 소송절차 진행에 번거로움이 발생할 수 있으므로 신중한 운영이 필요하다.

## 제3절 담보제공을 명하는 재판

### 1. 재판의 형식

#### 가. 소송비용의 담보

소송비용의 담보에 있어서 피고의 담보제공 신청이 있으면 그 허부를 ‘결정’으로 재판한다. 신청의 당부를 판단하기 위하여 필요한 때에는 양쪽 당사자를 심문할 수 있다. 법원은 심리의 결과 피고의 신청이 이유 없는 경우 또는 피고가 이미 응소하여 신청권을 상실한 경우에는 신청을 기각하거나 각

하하고, 신청이 이유 있을 때에는 원고에 대하여 결정으로 담보액과 담보제공의 기간을 정하여 담보의 제공을 명한다(민소 120조 1항). 민사소송법은 법원의 직권 담보제공결정의 시기에 관하여 제한을 두지 않았고, 법원은 피고가 담보제공 신청권을 상실한 후라도 직권으로 담보제공을 명할 수 있다.

담보제공 신청에 관한 결정에 대하여는 즉시항고를 할 수 있다(민소 121조). 직권에 의한 소송비용 담보제공에 대해서는 불복규정이 별도로 마련되어 있지 않으나 민사소송법 121조를 준용하여 즉시항고가 허용된다(대법원 2011. 5. 2. 자 2010부8 결정).

담보를 제공하여야 할 기간 이내에 원고가 이를 제공하지 아니하는 때에는 법원은 변론 없이 판결로 소를 각하할 수 있다. 다만 판결하기 전에 담보를 제공한 때에는 그러하지 아니하다(민소 124조).

#### 나. 가집행의 선고 관련 담보

가집행의 담보나 가집행을 면제받기 위한 담보의 경우에는 ‘판결 주문’에 담보액이 표시되어야 한다(민소 213조 3항). 이 경우에는 담보의 제공이 정지조건으로 되는 것이므로 담보제공의 기간을 정할 필요는 없다.

#### 다. 집행정지를 위한 담보

담보제공을 명하는 재판은 집행정지결정이 있기 전에 미리 독립한 결정으로 하는 방법(흔히 이를 ‘담보제공명령’이라 부른다)과 집행정지결정의 재판에 포함시켜 하는 방법이 있다. 전자의 경우에는 “신청인은 담보로 이 명령을 고지받은 날부터 ○일 이내에 ○○원을 공탁할 것을 명한다.”라고 하고, 후자의 경우에는 “신청인이 담보로 ○○원을 공탁할 것을 조건으로 …”라고 하는 것이 실무이다.

집행정지 결정에 앞서 담보제공명령을 발한 경우에 담보제공의무자가 소정의 기간 내에 담보를 제공하지 아니한 때에는 그 자체로서 집행정지결정

등의 신청을 각하한다. 소정의 기간을 경과하였더라도 아직 신청이 각하되지 아니한 동안에 담보를 제공하면 신청을 인용하는 것이 실무이다.

## 2. 담보액

### 가. 소송비용의 담보

소송비용의 담보에 있어서 담보액은 피고가 각 심급에서 지출할 비용의 총액을 표준으로 하여 정하여야 한다(민소 120조 2항).

실무상 담보액은 당사자의 합의를 유도하고, 합의가 이루어지지 않는 경우 보통 1심 내지 상소심의 변호사비용을 기준으로 하고, 만약 피고가 패소하여 상소할 경우에 소요되는 인지액 및 송달료 등 상소비용을 합한 액수까지 포함하여 신청하는 경우에는 그 비용까지 참작하여 결정하고 있다.

### 나. 가집행의 선고 관련 담보

가집행선고시 제공하는 담보는 가집행선고 있는 판결의 집행이 실시되는 경우에, 후일 가집행선고가 취소 또는 변경됨으로 말미암아 채무자가 입게 되는 손해액을 예상하여 담보액을 정한다.

가집행 면제의 선고시 제공하는 담보는 가집행을 하지 못함으로 인하여 승소채권자가 입게 되는 일체의 손해의 담보로서 채권 전액이 담보액으로 된다(민소 213조 2항).

### 다. 강제집행의 정지를 위한 담보

강제집행의 일시정지를 위한 담보의 경우에는 피담보채권인 손해배상청구권의 발생가능성과 그 예상액을 판단하여 담보액을 정한다.

집행정지로 인하여 상대방이 입게 되는 손해란 이론상으로는 집행정지의 잠정처분이 없었더라면 당장 강제집행을 할 수 있었을 터인데 집행정지로 말미암아 집행이 그만큼 지연됨으로써 입게 되는 손해를 의미한다. 담보의

대상이 되는 손해의 범위는 민법 393조에 의할 것이므로, 통상의 손해뿐 아니라 특별한 사정으로 인한 손해도 배상의무자가 그 사정을 알았거나 알 수 있었다면 거기에 포함될 수 있다(대법원 2017. 1. 13. 자 2016마1180 결정). 금전채권의 경우 통상 집행이 지연되는 기간에 해당하는 지연손해금 상당이 그 손해금이 된다(대법원 2025. 2. 13. 자 2024마7294 결정). 토지 인도 및 그 인도 시까지의 차임 상당액의 지급을 명한 가집행선고부 판결에 대한 강제 집행정지를 위하여 담보공탁을 한 경우, 그 토지의 인도집행이 지연됨으로 인한 손해에는 집행 정지 기간 내에 발생한 차임 상당의 손해가 포함되고, 그 차임 상당의 그 손해배상청구권은 인도집행정지를 위한 공탁금의 피담보 채무가 된다(대법원 2024. 1. 5. 자 2023마7070 결정).

그런데 집행정지 기간 동안에 채무자의 자력에 변동이 생겨 전혀 채권의 만족을 얻을 수 없게 되는 경우도 생길 수 있고 또 그동안 목적부동산이 처분되는 일도 있을 수 있다. 따라서 실무에서는 집행정지의 경우 대개 인용된 소송목적의 값 전액(다만 일부에 대하여 가집행의 선고가 있는 경우에는 그에 해당하는 값)을 담보로 제공하도록 하는 예가 많으나 채무자의 자력에 변동이 생길 가능성이 적은 경우 등에서는 담보액에 대한 신중한 심리가 요구된다.

담보제공자의 권리행사최고에 따라 담보권리자가 권리행사를 위하여 제기한 소송의 소송비용은 강제집행정지를 위하여 법원의 명령으로 제공된 담보 공탁금의 피담보채권이 된다(대법원 2004. 7. 5. 자 2004마177 결정). 반면 본안소송의 소송비용청구권(대법원 2011. 2. 21. 자 2010그220 결정)이나 강제 집행정지의 대상인 기본채권(대법원 2021. 11. 11. 선고 2018다250087 판결)에는 그 담보의 효력이 미치지 않는다.

### 3. 담보제공의 방식

담보의 제공은 금전 또는 법원이 인정하는 유가증권을 공탁하거나, 대법원규칙이 정하는 바에 따라 지급을 보증하겠다는 위탁계약을 맺은 문서를

제출하는 방법으로 한다. 다만 당사자들 사이에 특별한 약정이 있으면 그에 따른다(민소 122조).

담보제공을 명한 결정에서 정한 기간 내에 그 결정에서 정한 금액 등을 공탁하여야 한다.

#### 가. 금전 공탁에 의한 담보제공의 경우

실무상 자기앞수표는 유가증권이 아닌 현금으로 취급하고 있다. 그러나 가계수표의 경우에는 이를 현금과 같이 취급할 것인가에 관하여 특히 신중을 기할 것이다.

#### 나. 유가증권 공탁에 의한 담보제공의 경우

담보로서 유가증권의 공탁을 인정하는 때에는 그 종류와 수량을 명시한다. 예컨대 “중소기업금융채권 제○회 ○호 액면 ○○원권 ○○장” 등과 같다. 공탁할 유가증권은 담보로 하여야 할 성질상 환가가 용이한 것이어야 한다.

담보제공을 명하는 재판에서 구체적으로 유가증권의 종류·수량 등이 지정되어 있지 아니하면 담보제공자는 민사소송법 126조의 담보물변경 절차를 유추하여 공탁 전에 담보제공명령을 한 법원 또는 공탁서를 제출할 법원에 신고하여 그 종류·수량의 지정을 받아 공탁하여야 한다(다만 이에 대하여는 당사자가 자기 스스로 판단하여 상당하다고 인정되는 유가증권을 공탁하면 되고 만일 법원의 판단으로 부족하다고 생각되면 새로이 기간을 정하여 추가로 공탁할 것을 명할 것이라는 견해 또는 그 지정은 필요하나 담보제공명령을 한 법원만이 지정을 할 수 있다는 견해도 있다).

실무상으로는 국채나 공채가 주로 지정되고 있으나 반드시 이에 한하는 것은 아니다. 그러나 시세의 변동이 심한 주권과 같은 것은 피하는 것이 좋다. 그 가액은 액면가가 아니라 시장가격을 기준으로 하여 공탁할 수량을 정한다.

## 다. 지급보증위탁계약체결문서의 제출에 의한 담보제공의 경우

### (1) 지급보증위탁계약의 요건

민사소송법 122조의 규정 또는 이를 준용하는 민사소송법 127조, 214조, 502조 3항, 민사집행법 19조 3항의 규정에 따라 지급보증위탁계약을 체결한 문서를 제출하는 방법으로 담보를 제공하는 방식에 관하여 민사소송규칙 22조 및 ‘지급보증위탁계약체결문서의 제출에 의한 담보제공과 관련한 사무처리요령’에서 규정하고 있다.

‘지급보증위탁계약’은 담보제공명령을 받은 사람이 은행법의 규정에 따른 금융기관이나 보험회사와 체결한 것으로서 다음의 요건을 갖춘 것이어야 한다(민소규 22조 2항).

① 은행 등이 담보제공명령을 받은 사람을 위하여, 법원이 정한 금액 범위 안에서, 담보에 관계된 소송비용상환청구권에 관한 집행권원 또는 그 소송비용상환청구권의 존재를 확인하는 것으로서 확정판결과 같은 효력이 있는 것에 표시된 금액을 담보권리자에게 지급한다는 것, ② 담보취소의 결정이 확정될 때까지 계약의 효력이 존속된다는 것, ③ 계약을 변경 또는 해제할 수 없다는 것, ④ 담보권리자가 신청한 때에는 은행 등은 지급보증위탁계약을 맺은 사실을 증명하는 서면을 담보권리자에게 교부한다는 것

지급보증위탁계약을 맺은 문서로는 실무상 ‘보증서’라고 부르는 공탁보증보험증권이 일반적으로 사용되고 있다.

### (2) 보증서 제출에 의한 담보제공이 허용되지 아니하는 경우

법원은 당사자로부터 보증서의 제출에 의한 담보제공의 허가신청이 있으면 원칙적으로 이를 허가할 것이나, 다음의 경우에는 그러하지 아니하다(보증서예규 5조).

① 가집행선고 있는 판결에 대하여 상소제기가 있는 때의 강제집행의 일시정지를 위한 담보

② 청구이의의 소의 제기가 있는 때의 강제집행의 일시정지를 위한 담보



## ③ 그 밖에 담보제공의 성질상 위에 준하는 경우

다음의 경우에는 성질상 보증서 제출이 허용되지 아니함을 유의하여야 한다(보증서예규 5조의2).

① 민사소송법 299조 2항의 규정에 따른 소명에 갈음한 보증

② 매각허가결정에 대한 항고에 있어서의 보증(민집 130조 3항, 268조, 269조)

③ 가압류해방금액(민집 282조)

나아가 담보제공의무자가 금융기관 또는 보험회사인 경우에, 자기를 지급보증위탁계약의 양쪽 당사자로 하는 보증서의 제출로써 담보를 제공하는 것은 담보제공의무자와 지급보증을 하는 자가 동일인이어서 담보로서의 가치가 없으므로 허용되지 아니한다.

반면에, 실무상 외국법인이 제기한 국제거래소송에서 자주 발생하는 소송비용담보의 경우 종래 이를 위한 공탁보증보험증권 상품이 판매되지 않아 현금공탁을 하지 못하는 경우에 재판을 포기하는 사례가 많이 있었으나 현재는 그러한 상품이 개발되었으므로, 신청이 있으면 보증서 제출에 의한 담보제공 신청을 원칙적으로 허가하는 것이 바람직하다.

## (3) 법원의 허가

지급보증위탁계약을 맺은 문서를 제출하는 방법으로 담보를 제공하려면, 담보제공의무자가 사건 신청의 서면에 또는 사건 신청 후 별개의 신청서로 법원에 허가신청을 함으로써 미리 법원의 허가를 받아야 한다(민소규 22조 1항).

보증서를 제출하는 방법으로 담보를 제공하기 위한 허가신청에 대하여 법원이 허가결정을 하는 경우의 양식은 다음과 같다(보증서예규 3조).

① 담보제공명령 후에 허가결정을 허가신청서에 하는 경우: [전산양식 A3140]

② 담보제공명령 후에 허가결정을 별개의 서면으로 하는 경우: [전산양식

A3141]

③ 담보제공명령과 동시에 허가결정을 하는 경우: [전산양식 A3142]

## 제4절 담보제공의 절차

### 1. 공탁 또는 보증서 등의 제출

#### 가. 금전 또는 유가증권의 공탁

##### (1) 공탁기관

공탁을 할 공탁소에 관하여는 특별한 제한규정이 없으므로 담보제공자가 임의로 정한 공탁소에 공탁하면 되는데 대개 담보제공명령을 발한 법원 소재지의 공탁소에 공탁하고 있다. 공탁사무는 지방법원장(지원장)이 지정하는 소속 법원서기관 또는 법원사무관, 시·군법원의 경우에는 지방법원장(지원장)이 지정하는 소속 법원주사 또는 법원주사보가 행하므로(공탁법 2조), 그 지정을 받은 자가 공탁관으로서 공탁소가 된다.

##### (2) 공탁절차

담보제공을 위한 공탁의 절차는 공탁법과 공탁규칙 20조, 26조 내지 29조에서 정한 바에 따른다. 즉 공탁을 하려는 사람은 공탁규칙 소정의 공탁서 2통을 공탁관에게 제출하고, 공탁관으로부터 공탁을 수리한다는 뜻 등 소정의 내용이 기재된 공탁서 1통을 교부받은 다음 공탁물을 첨부하여 공탁물 보관자에게 제출하며, 공탁물 보관자로부터 공탁물을 납입받았다는 취지가 기재된 공탁서를 반환받는다. 이와 같이 반환받은 공탁서를 법원에 제출함으로써 담보제공이 이루어진다.

한편 민사소송법에는 당사자에 한하여 담보제공을 할 수 있다는 규정이나 제3자가 담보제공을 하는 것을 금하는 규정이 없으므로, 당사자 본인에게 공탁명령이 나간 경우에도 제3자는 당사자를 대신하여 공탁할 수 있다. 이

경우 법원의 허가나 담보권자의 동의는 필요 없으나 제3자가 당사자를 대신하여 공탁함을 공탁서에 기재하여야 할 것이다.

#### 나. 보증서(지급보증위탁계약을 맺은 문서) 제출에 의한 담보제공

법원의 허가결정에 따라 보증서를 제출하는 방법으로 담보를 제공하는 자는 보증서원본을 법원에 제출하여야 한다. 담당 법원사무관등은 당사자가 제출한 보증서원본에 접수인을 날인하여 이를 사건기록에 편철한 다음 담당 판사에게 회부한다(보증서예규 4조).

#### 다. 당사자들 사이에 특약이 있는 경우의 담보제공

담보제공에 관하여 특약이 있어(민소 122조 단서) 법원의 담보제공명령에 계약에 의한 담보의 제공(보증인을 세우거나 담보물권을 설정하는 등)이 명하여진 때에는 그 담보계약서와 그 계약의 이행을 증명하는 서면을 제출하여야 한다.

## 2. 증명서의 발급

공탁서 또는 보증서 등을 제출받는 법원은 소송비용의 담보, 가집행선고에 관련된 담보인 경우에는 담보제공을 명한 수소법원이다. 강제집행을 정지하는 담보의 제공이나 공탁은 원고나 피고의 보통재판적이 있는 곳의 지방법원 또는 집행법원이다(민소 502조).

강제집행을 정지하기 위하여 명하여진 담보를 제공하거나 공탁을 한 때에는 법원은 당사자의 신청에 따라서 증명서를 주어야 한다. 당사자는 이러한 담보제공 증명서를 집행기관에 제출함으로써 집행정지를 할 수 있다.

## 제5절 담보권의 실행

### 1. 의 의

‘담보권의 실행’이란 담보권을 행사할 수 있는 사유가 발생한 때, 즉 소송비용의 담보에 있어서는 원고가 패소하여 원고가 소송비용의 부담 재판을 받은 때 또는 강제집행절차에 있어서 담보제공으로써 보전할 손해가 담보권리자에게 발생한 때에 담보권리자가 제공된 담보로부터 소송비용 또는 손해를 변상받는 절차이다.

### 2. 금전·유가증권 공탁에 의한 담보제공의 경우

재판상 담보공탁(금전)의 피공탁자(담보권리자)가 담보권을 실행하는 방법 및 공탁관의 관련 업무처리지침을 규정하기 위하여 ‘재판상 담보공탁금의 지급청구절차 등에 관한 예규’가 제정되어 있다.

재판상 담보공탁이란 당사자의 소송행위(소송비용의 담보)나 법원의 처분(강제집행의 정지·실시·취소 등)으로 인하여 담보권리자가 받게 될 손해를 담보하기 위한 금전공탁을 말한다. 담보권리자는 소송비용 또는 그 받은 손해에 관하여 제공된 담보물에 대하여 질권자와 동일한 권리를 가진다(민소 123조, 502조 3항, 민집 19조 3항). 예컨대 가집행선고부 판결에 대한 강제집행정지를 위하여 공탁한 담보(민소 501조)는 강제집행정지로 인하여 채권자에게 생길 손해를 담보하기 위한 것으로서 정지의 대상인 기본채권 자체를 담보하는 것은 아니므로, 채권자는 강제집행정지로 인한 손해배상청구권에 한하여서만 질권자와 동일한 권리가 있다(재판담보예규 2. 나.).

담보권리자의 담보권 실행방법은 직접 출급 청구를 하는 경우와 질권실행을 위한 압류 등을 하는 경우의 2가지가 있다(재판담보예규 4.).

### 가. 직접 출급 청구를 하는 경우

공탁관은 재판상 담보공탁의 피공탁자(담보권리자)가 공탁원인 사실에 기재된 피담보채권이 발생하였음을 증명하는 서면을 제출하여 공탁금을 출급 청구(청구서에 회수청구라고 기재한 때에도 출급청구한 것으로 본다)한 경우에는 공탁금을 피공탁자에게 교부한다. 그러나 담보취소결정정보 및 확정증명이 이미 제출된 경우에는 그러하지 아니한다[재판담보예규 4. 가. (1)].

피담보채권에 관한 확정판결(이행판결과 확인판결을 모두 포함), 이에 준하는 서면(화해조서, 조정조서, 공정증서 등) 또는 공탁자의 동의서(인감증명서 첨부)는 특별한 사정이 없는 한 ‘피담보채권이 발생하였음을 증명하는 서면’으로 본다[재판담보예규 4. 가. (2)]. 가처분채권자가 가처분으로 인하여 가처분채무자가 받게 될 손해를 담보하기 위하여 법원의 담보제공명령으로 일정한 금전을 공탁한 후 파산선고를 받은 경우, 가처분채무자로서는 가처분채권자의 파산관재인을 상대로 그 담보공탁금의 피담보채권인 손해배상청구권의 존부에 관한 확인의 소를 제기하여 확인판결을 받는 등의 방법에 의하여 피담보채권이 발생하였음을 증명하는 서면을 확보한 후 담보공탁금에 대하여 직접 출급청구를 하는 방식으로 그 담보권을 실행할 수 있다(대법원 2015. 9. 10. 선고 2014다34126 판결).

또한 금전 및 이에 대한 다 갚는 날까지의 지연손해금의 지급을 명한 판결이나 건물인도 및 그 인도시까지의 차임 상당액의 지급을 명한 가집행정고부 판결에 대한 강제집행정지를 위하여 담보공탁을 한 경우, 그 가집행이 지연됨으로 인한 손해에는 반대의 사정이 없는 한 집행정지의 효력이 있는 기간 내에 발생한 지연손해금이나 차임 상당의 손해가 포함되므로, 이에 관한 지급을 명한 확정판결 부분은 강제집행정지를 위한 담보공탁의 피담보채권이 발생하였음을 입증하는 서면이 된다[대법원 2000. 1. 14. 선고 98다24914 판결 참조, 재판담보예규 4. 가. (3)].

공탁관은 피공탁자가 제출한 서면이 담보공탁의 피담보채권이 발생하였음

을 증명하는 서면에 해당하는지 여부를 신중히 판단하여야 하며, 피공탁자가 출급청구한 금액 중 일부에 관하여 피담보채권이 발생된 것으로 인정되는 경우에는 그 범위 내에서 출급청구를 수리하되, 피담보채권이 발생하였는지 여부가 명확하지 아니한 경우에는 출급청구를 수리하지 아니한다[재판 담보예규 4. 가. (4)].

#### 나. 질권실행을 위한 압류 등을 하는 경우

공탁관은 담보공탁의 피공탁자가 피담보채권에 터 잡아 민사집행법 273조에서 정한 채권에 대한 강제집행절차에 따라 공탁자의 공탁금회수청구권을 압류하고 추심명령이나 확정된 전부명령을 얻어 공탁금 출급청구(청구서의 표시를 회수청구라고 기재한 때에도 같다)를 한 경우에도 공탁물을 피공탁자에게 교부한다. 이 경우에, 피공탁자는 공탁금출급청구서와 함께 질권(담보권) 실행을 위한 압류명령 정보, 추심명령 또는 전부명령 정보, 위 명령의 송달증명, 전부명령에 관한 확정증명을 제출하여야 한다(담보권실행의 신청을 할 때 담보권의 존재를 증명하는 서류를 제출하므로 따로 담보취소결정을 받을 필요는 없다. 재판담보예규 4. 나.). 가처분채권자가 가처분으로 인하여 가처분채무자가 받게 될 손해를 담보하기 위하여 법원의 담보제공명령으로 일정한 금전을 공탁한 후 파산선고를 받은 경우, 가처분채무자로서는 가처분채권자의 파산관재인을 상대로 그 담보공탁금의 피담보채권인 손해배상청구권의 존부에 관한 확인의 소를 제기하여 확인판결을 받는 등의 방법에 의하여 피담보채권이 발생하였음을 증명하는 서면을 확보한 후, 민법 354조에 의하여 민사집행법 273조에서 정한 담보권 존재 증명 서류로서 위 서면을 제출하여 채권에 대한 질권 실행 방법으로 공탁금회수청구권을 압류하고 추심명령이나 확정된 전부명령을 받아 담보공탁금 출급청구를 함으로써 담보권을 실행할 수 있다(대법원 2015. 9. 10. 선고 2014다34126 판결).

다만 실무상 담보권리자는 담보제공자(공탁자)가 공탁소에 대해 가지는 공

탁물회수청구권상에 채권질권을 가지는 것이라는 전제 아래, 그 담보권 행사의 사유가 발생하면 담보권리자가 담보제공자의 공탁물회수청구권을 압류하고 전부 또는 추심명령을 얻어(민집 223조, 227조, 229조, 민법 354조) 스스로 담보취소결정을 구한 후(대법원 1969. 11. 26. 자 69마1062 결정 참조), 공탁물을 교부받는 방법으로 담보권을 실행하는 방식도 많이 활용되고 있다. 이 경우에는 담보권의 실행이 아닌 이른바 원본채권의 실행이므로, 담보권리자는 공탁금회수청구서와 함께 담보취소 결정정보 및 확정증명, 질권(담보권) 실행이 아닌 일반 강제집행절차에 의한 압류명령 정보, 추심명령 또는 전부명령 정보, 위 명령의 송달증명, 전부명령에 관한 확정증명을 제출하여야 하나(재판담보예규 5.), 채권(공탁물회수청구권)의 압류 등 신청에 있어서는 반드시 집행권원이 있어야 하는 것도 아니고 집행문을 부여받을 필요도 없다.

### 3. 지급보증위탁계약을 맺은 문서(보증서)에 의한 담보제공의 경우

보증서를 제출하는 방식으로 지급보증위탁계약을 맺은 문서로 제공하는 방법으로 담보가 제공된 경우에는 담보권리자는 담보권을 행사할 수 있는 사유가 발생한 사실을 집행권원 또는 그 권리의 존재(피담보채권의 발생)를 확인하는 것으로서 확정판결과 같은 효력이 있는 것으로 증명하여 은행·보험회사 등에 제시하게 된다. 은행·보험회사 등은 이러한 문서를 제시받을 때에는 그 내용에 관한 실체적인 심사를 하지 아니하고 바로 법원이 정한 금액을 한도로 하여 그 문서에 표시된 금액을 지급하여야 한다.

제14장

민사소송법상의 담보

## 제6절 담보의 취소

### 1. 의 의

‘담보의 취소’란 앞에서 본 담보권의 실행의 경우에 대응하는 것으로서 담

보제공자(공탁자)가 담보하여야 할 사유가 소멸된 경우 제공한 담보를 반환 받는 절차이다.

민사소송법은 담보제공자가 담보하여야 할 사유가 소멸된 것을 증명한 때 또는 담보권리자의 동의가 있음을 증명한 때에는 법원은 신청에 의하여 담보취소의 결정을 하여야 한다고 규정하여(민소 125조 1항, 2항), 반드시 법원의 결정을 거치도록 하고 있다.

## 2. 담보취소신청

담보취소신청을 할 수 있는 사람은 담보를 제공한 사람 또는 그 승계인이다. 승계인은 포괄승계인은 물론, 담보물반환청구권(공탁물회수청구권)의 양수인 및 압류·전부·추심명령을 받은 사람과 같은 특정승계인을 포함한다. 담보물회수청구권에 대하여 압류·추심명령이 있으면 담보취소 신청은 추심채권자만 제기할 수 있고, 담보제공자는 담보취소를 신청할 당사자적격을 상실한다(대법원 2015. 10. 29. 자 2015카담39 결정). 담보권리자가 담보제공자의 담보물회수청구권에 관하여 압류·추심 또는 전부를 받은 경우 스스로 담보취소신청을 할 수 있다(대법원 1971. 4. 16. 자 71스4 결정). 제3자가 담보를 제공한 경우 채권자가 그 공탁금회수청구권이 채무자에게 귀속됨을 전제로 채권압류 및 추심명령을 받았더라도, 그 채권자는 담보제공자인 제3자의 승계인에 해당한다고 볼 수 없다(대법원 2018. 9. 18. 자 2018카담10 결정).

수인의 공탁자가 담보를 위한 공탁을 하면서 각자의 공탁금액을 나누어 기재하지 않고 공동으로 하나의 공탁금액을 기재한 경우에 공탁자들은 균등한 비율로 공탁한 것으로 보아야 하고, 공탁자들 내부의 실질적인 분담금액이 다르다고 하더라도 이는 공탁자들 내부 사이에 별도로 해결하여야 한다(대법원 2015. 9. 10. 선고 2014다29971 판결). 이 경우 담보취소 사유가 있으면 공동공탁자 중 1인은 균등한 비율에 의한 자신의 부담부분에 해당하는 공탁금에 관하여 단독으로 담보취소를 신청할 수 있다(공탁선례 201510-1호).



승계인 또는 대리인이 신청하는 경우에는 신청권 있음을 증명하기 위하여 가족관계등록사항증명서, 법인등기사항증명서, 담보물 반환청구권의 양도증이나 양도통지서, 압류·전부명령의 등본 및 그 우편송달통지서와 확정증명서, 위임장 등을 제출하여야 한다.

담보취소신청사건은 담보제공결정을 한 법원 또는 그 기록을 보관하고 있는 법원이 관할한다(민소규 23조 1항). 여기서 '담보제공결정을 한 법원 또는 그 기록을 보관하고 있는 법원'은 수소법원을 의미하고 이는 직분관할로서 성질상 전속관할이다(대법원 2011. 6. 30. 자 2010마1001 결정). 신청에는 1,000원의 인지를 붙여야 하고(인지 9조 5항 4호, 인지액·편철방법예규), 사건 부호는 '카담'이며, 신청사건으로 전산입력한다.

### 3. 담보취소의 요건

담보취소의 요건으로는 담보 사유의 소멸(민소 125조 1항), 담보권리자의 동의(2항), 권리행사 최고기간의 만료(3항)를 들 수 있다.

#### 가. 담보하여야 할 사유의 소멸

담보하여야 할 사유의 소멸이란 담보를 제공함으로써 잠정적으로 허용되었던 담보제공자의 행위가 이후의 절차에서 그에게 유리하게 확정되었기 때문에 담보제공의 필요성이 없게 되는 것을 말한다. 이는 그 담보를 제공할 원인이 부존재인 경우는 물론이고 그 후 담보의 존속을 계속시킬 원인이 부존재하게 된 경우 또는 장래에 있어서 손해발생의 가능성이 없게 된 경우 등을 의미하는 것이다(대법원 2006. 6. 30. 자 2006마257 결정). 신청인은 판결의 정본·등본·초본, 주문증명서·확정증명서, 화해·인낙·포기·조정조서의 정본·등본·초본 등을 제출함으로써 그 사유를 증명할 수 있다. 다음에서는 담보제공의 사유에 따라 나누어 살펴본다.

### (1) 소송비용의 담보

담보의무자(제공자)인 원고가 국내에 주소·사무소 또는 영업소를 가지게 된 때, 소송구조의 결정(민소 128조)을 받은 때, 원고가 전부 승소하여 소송비용이 피고의 부담으로 된 때, 원고가 소송비용의 일부 부담의 판결을 받았으나 원고청구의 인용액이 원고가 부담할 소송비용을 초과하게 된 때에는 담보의 필요성이 없어진다.

### (2) 가집행선고 관련하여 제공된 담보

가집행을 위하여 제공된 담보에 있어서는 가집행선고부 판결이 취소됨이 없이 원고가 승소의 확정판결을 받은 때에, 가집행을 면하기 위해 제공된 담보에 있어서는 가집행선고부 판결을 취소하는 판결이 확정된 때에 각각 담보사유가 소멸된다.

### (3) 가집행의 정지를 위해 제공된 담보

상소심의 소송절차에서 담보제공자의 승소판결이 확정된 경우 또는 이와 같이 볼 수 있는 경우에는 담보의 사유가 소멸된다(대법원 2014. 8. 14. 자 2014카담37 결정). 가집행선고부 제1심판결이 항소심판결에 의하여 취소되었다 하더라도 그 항소심판결이 미확정인 상태에서는 사유가 소멸되었다고 볼 수 없다(대법원 1999. 12. 3. 자 99마2078 전원합의체 결정). 이 경우 그 항소심판결이 그대로 확정되어야 비로소 담보사유가 소멸한 것이 된다. 다만 담보권리자가 별도로 담보제공자를 상대로 담보 목적의 손해배상을 청구한 경우 그 기각판결이 확정되면 그때 담보의 사유가 소멸되었다고 볼 수 있다(대법원 1992. 1. 31. 자 91마718 결정). 가집행선고부 제1심판결에 대한 피고의 항소가 기각된 후 상고심이 담보제공을 조건으로 제1심판결의 강제집행을 정지한 다음 항소심판결을 파기환송한 경우에도 담보의 사유가 소멸되었다고 볼 수 없다(대법원 2008. 11. 13. 자 2008카담19 결정). 반면 항소심의 가집행선고부 판결에 대한 강제집행정지를 위해 제공된 담보는 상고심에서 그 항소심 판결이 파기되면 담보의 사유가 소멸한다(대법원 1984. 4. 26. 자 84

마171 결정).

(4) 청구이의의 소(민집 44조) 또는 집행문부여에 대한 이의의 소(45조)를 제기한 당사자가 제1심에서 강제집행정지를 구하기 위하여 제공한 담보

이러한 담보는 항소심에서 다시 강제집행정지를 위한 담보가 제공되었다 하더라도 그 담보의 사유가 소멸되는 것이 아니고, 담보를 제공한 당사자가 승소판결을 받아 종국적으로 확정되거나 이와 같이 볼 수 있는 경우에만 담보의 사유가 소멸한다. 제3자의이의 소(민집 48조)의 경우도 이에 준한다.

(5) 가압류·가처분을 위해 제공된 담보

이러한 담보는 본안소송이 계속 중인 한 그 담보사유가 소멸되지 아니하고(대법원 1959. 7. 5. 자 4291민재항213 결정), 채권자(담보제공자)가 본안에서 승소의 확정판결을 받은 때 담보사유가 소멸된 것으로 인정되는데, 이행권고결정이 확정된 경우에도 담보사유가 소멸된 것으로 볼 수 있다(대법원 2006. 6. 30. 자 2006마257 결정). 지급명령이 확정된 경우에도 마찬가지로 보아야 한다.

가압류·가처분집행이 불능인 경우(대법원 1967. 4. 19. 자 67마154 결정), 가압류·가처분명령이 집행되지 아니하고 집행기간을 도과한 경우(대법원 1967. 12. 29. 자 67마1009 결정), 가압류·가처분의 집행불능 후 가압류·가처분을 취하한 경우(대법원 1981. 12. 22. 자 81마290 결정), 채권자(담보제공자)가 제1심에서 승소하고 가압류가 가집행으로 이행한 경우 또는 본안 제1심에서 승소하고 항소심 계속 중 가압류·가처분신청을 취하여 그 집행이 취소된 경우 등에는 그 자체만으로 담보사유가 소멸되지 아니한다. 가압류 채권자가 가압류 청구채권 중 일부에 대해서만 본안소송을 제기하였다고 하여 그 사실만으로 담보사유가 소멸되었다고 할 수 없다(대법원 2008. 7. 1. 자 2008마711 결정).

병합청구의 본안소송에서 일부 승소하였다 하여도 나머지 일부가 계속 중인 한, 담보사유가 소멸되었다 할 수 없다(대법원 1967. 1. 19. 자 66마1035

결정). 담보제공자 또는 담보권리자가 여러 사람 있는 경우 그들 사이에 불가분 또는 연대관계가 없는 한 담보소멸의 여부는 개별적으로 판단하여야 한다. 가압류·가처분 채권자가 본안의 승소판결을 받아 일단 확정되면 담보사유는 소멸하는 것이므로, 그 후 항소의 추후보완이나 재심의 소가 제기되어 있어 사건이 계속 중이더라도 영향은 없다.

가압류·가처분사건의 본안소송이 화해에 의하여 종료되는 경우에, 그 화해조항의 일부로서 가압류·가처분을 위한 담보공탁에 관한 약정이 있으면 그에 따르면 된다. 즉 화해조항으로 담보권리자가 담보취소에 동의한다는 기재가 있다면 그 화해조서가 동의의 증명으로 인정된다. 그러한 정함이 없는 경우에는 특별한 사정이 없는 한 담보권리자가 손해배상청구권을 포기하였다고 추정하여 담보사유가 소멸하였다고 보는 것이 다수의 견해이다.

#### (6) 가압류·가처분명령의 취소를 위하여 제공한 담보(민집 286조 5항, 301조)

법원이 가압류·가처분명령에 대한 이의신청 사건에서 가압류·가처분을 취소하는 결정을 하면서 적당한 담보제공(민집 286조 5항, 301조)을 명한 경우에, 제공된 담보는 가압류·가처분의 취소 자체로 인하여 가압류·가처분 채권자가 입을 손해를 담보하기 위한 것이고, 가압류·가처분을 취소하는 재판이 부당한 것으로 판명되는 경우에 한하여 그로 인하여 가압류·가처분채권자가 입게 될 손해만을 담보하는 것이 아니므로 가압류·가처분을 취소하는 결정이 확정되었다는 이유만으로 담보의 사유가 소멸된 것으로 보아 담보취소의 결정을 할 수는 없다(대법원 1992. 12. 22. 자 92마782 결정). 가압류·가처분채권자는 가압류·가처분 취소로 인하여 입은 손해배상을 청구하는 소송을 제기하여 승소판결을 받은 경우에는 위 담보에 대하여 권리를 행사할 수 있다.

#### 나. 담보권리자의 동의

담보제공자는 담보취소에 관한 담보권리자의 동의를 얻은 것을 증명하여

담보취소의 신청을 할 수 있다(민소 125조 2항). 동의를 증명은 서면에 의하는 것이 실무이다. 본안에서 재판상 화해가 성립되고 화해조항으로서 담보취소에 동의하고 담보취소결정에 대한 항고권을 포기한다는 기재가 있으면 그 화해조서가 동意的 증명으로 인정된다. 담보권리자의 동의는 공탁물에 대한 권리의 포기라고 인정되므로 동이가 있는 이상 법원은 본안사건 종료 전이라 하더라도 담보취소결정을 할 수 있다.

담보취소의 동의는 담보의 전부에 관하여 함이 보통이겠지만, 담보의 일부에 관한 동의도 허용되므로, 이 경우엔 담보의 일부 취소 결정을 할 수 있다.

담보권리자가 담보제공자의 공탁금 회수청구권을 압류·추심 또는 전부받아 담보취소를 신청하는 경우에는 담보권리자와 담보취소신청인이 동일인이므로 별도의 동의서를 제출할 필요가 없다는 것이 실무이다.

#### 다. 권리행사 최고기간의 만료

소송완결 후 담보제공자의 신청이 있는 때에는 법원은 담보권리자에게 일정한 기간 이내에 그 권리를 행사할 것을 최고하고, 담보권리자가 그 행사를 하지 아니하는 때에는 담보취소에 대한 담보권리자의 동이가 있는 것으로 본다(민소 125조 3항).

##### (1) 소송의 완결

‘소송의 완결’이란 담보권의 객체인 피담보채권(소송비용상환청구권 또는 손해배상청구권)이 확정되고 그 액수의 계산에 장애가 없어진 상태를 말한다.

소송비용의 담보에 있어서는 소송절차가 종결되어 소송비용 부담의 재판이 내려진 경우에 소송이 완결된다.

가압류·가처분사건의 경우 가압류·가처분의 본안소송이 계속 중이라면 가압류·가처분이 이의신청 등을 통해 취소 확정되고 그 집행이 해제되었다고 하더라도 담보권리자에게 그 권리행사를 최고할 수 있는 소송완결이 있다고 할 수 없고, 계속 중인 본안사건까지 확정되어야만 소송의 완결로 인정

할 수 있다(대법원 2010. 5. 20. 자 2009마1073 전원합의체 결정). 가압류·가처분의 취하가 있더라도 본안소송이 계속 중이라면 소송완결이 있다고 할 수 없다. 다만 본안소송이 제기되기 전에 가처분사건이 완결된 경우에는 그 가처분사건의 완결로써 소송완결이 있는 것으로 해석함이 옳다.

청구이의의 소(민집 44조), 집행문부여에 대한 이의의 소(45조)에 있어서 집행정지를 위한 담보는 그 소송에서 원고 패소 판결이 확정된 때에 '소송이 완결'되었다고 할 수 있다. 그러나 제3자의이의 소(48조)의 강제집행정지를 위한 담보는 이의가 배척되고 집행절차가 배척된 것만으로는 소송이 완결되었다고 할 수 없고, 매각허가결정에 의하여 매각대금이 확정되어야 비로소 정지로 인한 손해액을 산정할 수 있기 때문에 매각절차가 완결되어야 '소송의 완결'로 볼 수 있다.

## (2) 권리행사의 최고

권리행사최고는 신청인의 신청에 의하여 법원이 담보권리자에게 한다. 권리행사최고신청에는 1,000원의 인지를 붙여야 하며, 최고서를 송달할 비용을 예납하여야 하고, 법원은 이를 담보취소신청사건과는 별개의 신청사건(사건부호 '카담')으로 접수한다. 다만 담보취소신청과 권리행사최고를 동시에 신청한 경우에는 사건명을 '권리행사최고 및 담보취소'라고 1개만 기재한다(사건부호예규).

법원은 사건이 완결되었는지 여부를 조사하고 완결되었다고 인정되는 경우에는 권리행사최고서[전산양식 A1310]를 작성하여 송달하고, 그 사본을 기록에 편철하여 놓는다. 권리행사기간은 1주일 내지 2주일 정도가 보통이다. 담보권리자의 주소불명 등 공시송달의 요건이 있는 때에는 신청에 의해 공시송달 할 수 있다. 보전처분의 담보와 관련하여 보전처분 사건에서의 공시송달명령을 권리행사최고 사건에 원용할 수 없고 다시 공시송달명령을 하여야 하고, 다만 권리행사최고 사건의 공시송달명령은 그에 이은 담보취소 절차에 원용할 수 있다는 것이 실무이다.

### (3) 담보권리자의 권리불행사

권리행사는 피담보채권 자체에 대한 재판상의 청구이어야 한다(대법원 1992. 10. 20. 자 92마728 결정). 피담보채권에 대한 소제기, 지급명령, 제소전화해 신청 등이 이에 해당한다. 담보권리자가 재판상 권리행사를 하지 않고 단지 소제기 준비 중에 있다는 예고를 하는 것만으로 권리행사를 하였다고 볼 수 없다(대법원 1978. 10. 26. 자 78마263 결정). 소송비용담보의 경우에는 소송비용액확정신청이 권리행사가 될 것이다. 반면 강제집행정지를 위한 담보의 경우 본안소송에 대한 소송비용액확정결정 신청을 하였다고 하여 권리행사를 하였다고 볼 수 없고(대법원 2011. 2. 21. 자 2010그220 결정), 담보권리자가 강제집행정지의 대상이 되었던 확정판결에 기하여 담보제공자의 공탁금 회수청구권에 대하여 채권압류 및 전부명령을 신청한 것은 집행정지로 인한 손해배상채권 자체를 행사한 것이 아니므로 권리행사를 하였다고 볼 수 없다(대법원 2015. 4. 28. 자 2015카담9 결정). 다만 지연손해금의 지급을 명한 가집행선고부 판결에 대한 강제집행정지를 위하여 담보공탁을 한 경우 그 지연손해금 상당의 손해배상청구권은 담보공탁의 피담보채권이 되므로, 위 판결이 확정되어 담보권리자가 확정판결을 제출하면 권리행사를 하였다고 볼 수 있다(대법원 2025. 2. 13. 자 2024마7294 결정).

권리행사기간 안에 일단 담보권리자에 의한 소의 제기가 있었으나, 그 후 그 소가 취하되거나 취하간주되어 그 권리행사가 처음부터 없었던 것으로 보는 때에는 그 권리행사기간이 경과함으로써 담보권리자가 담보취소에 동의한 것으로 간주하여야 한다(대법원 2008. 3. 17. 자 2008마60 결정). 이는 담보권리자가 제기한 소가 부적법 각하되는 등의 이유로 적법한 권리행사가 없게 된 경우에도 마찬가지이다(대법원 2016. 1. 29. 자 2015마1731 결정).

최고에서 정한 권리행사기간 안에 권리를 행사하지 않았더라도 담보취소 결정을 하기 전에 권리를 행사한 사실을 증명하면 담보취소결정을 할 수 없다. 또 담보취소결정이 있었더라도 그 결정이 확정되기 전에 권리행사가 있

으면 담보취소결정은 유지될 수 없고, 이는 재항고심에 이르러 비로소 권리 행사를 하면서 이를 증명하는 서면을 제출한 경우에도 마찬가지이다(대법원 2000. 7. 18. 자 2000마2407 결정).

최고를 받은 담보권리자가 소의 제기, 지급명령의 신청 등으로 권리행사를 한 경우에도 그 권리 주장의 범위가 담보공탁금액 중 일부에 한정되어 있을 때에는 그 초과 부분에 대해서는 담보취소에 대한 동의가 있다고 보아야 하므로, 법원은 그 부분 일부 담보를 취소하여야 한다(대법원 2017. 1. 13. 자 2016마1180 결정). 예를 들어 가압류의 담보로 공탁금이 제공된 후 담보 제공자의 권리행사최고에 대하여 담보권자가 부당한 가압류의 집행에 따른 손해에 대한 확정 판결문을 제출한 경우 담보공탁금 중 위 확정판결의 원리금을 초과한 범위에 대하여는 담보취소에 대한 동의를 하였다고 보아야 한다(대법원 2022. 3. 22. 자 2020마1343 결정).

담보의 대상이 되는 손해의 범위는 민법 393조에 따라 통상의 손해뿐 아니라 특별한 사정으로 인한 손해도 배상의무자가 그 사정을 알았거나 알 수 있었다면 거기에 포함될 수 있고, 따라서 담보권리자의 주장 자체에 의하더라도 강제집행정지로 인하여 발생할 수 없음이 명백하다는 등의 특별한 사정이 없는 한, 담보권리자가 소송에서 주장한 손해가 통상의 손해가 아니라는 이유만으로 담보에 대한 권리행사의 효력이 미치지 않는다고 단정할 것은 아니며, 담보권리자가 주장한 권리 내용에 지연손해금이나 소송비용이 포함되어 있는 등으로 구체적인 손해액을 확정하기 어려운 경우에도, 법원 으로서는 제출된 자료를 기초로 상당하다고 인정되는 범위에서 권리행사가 있었던 것으로 보고 이를 초과하는 부분에 대한 담보를 취소하여야 한다(대법원 2017. 1. 13. 자 2016마1180 결정).

#### 4. 담보취소 신청에 대한 재판

법원은 신청이 적법하고 담보취소의 요건이 구비되어 있다고 인정되는 때



에는 담보취소결정을 한다(민소 125조). 실무상 서면심리에 의하는 것이 통례이다. 결정서 양식은 그 취소 사유에 따라 담보사유가 소멸한 경우[전산양식 A1311], 담보권리자가 동의한 경우[전산양식 A1312], 권리행사최고기간이 만료한 경우[전산양식 A1313]로 나뉘어 마련되어 있다.

이 결정은 양쪽 당사자에게 정본을 송달하여 고지한다. 담보취소결정이 내려진 후 그 송달 전에 피신청인이 사망하였다면 담보취소결정은 상속인에게 송달하여야 하고, 상속인이 즉시항고하려면 소송수계를 하여야 한다(대법원 2009. 6. 26. 자 2008마1773 결정).

담보취소를 인용한 결정에 대하여는 즉시항고(민소 125조 4항)로 불복할 수 있다. 다만 담보제공자는 담보취소결정에 대하여 항고 또는 재항고로 불복할 이익이 없는데, 담보취소결정은 담보제공자로 하여금 담보물을 회수할 수 있는 지위 내지 상태에 놓이도록 하는 것일 뿐 그 담보물의 귀속을 정하는 것은 아니기 때문이다(대법원 2008. 2. 29. 자 2007마1438 결정). 담보제공자의 포괄승계인이나 담보물회수권에 관하여 압류·전부명령을 받은 특정승계인도 담보취소결정에 대하여 항고 또는 재항고로 불복할 이익이 없다(대법원 2011. 1. 13. 자 2010마1367 결정).

담보취소결정이 확정되면 담보제공자는 담보취소결정의 등본 및 확정증명서와 함께 공탁서를 공탁소에 제출하여 공탁물의 회수를 청구할 수 있다.

담보취소 신청을 기각·각하한 결정에 대하여는 통상항고(민소 439조)로 불복할 수 있다(대법원 2006. 10. 13. 자 2006마755 결정).

## 제7절 담보물변경

법원은 담보제공자의 신청에 따라 결정으로 공탁한 담보물을 바꾸도록 명할 수 있다. 다만 당사자가 계약에 의하여 공탁한 담보물을 다른 담보로 바

꾸짖다고 신청한 때에는 그에 따른다(민소 126조).

공탁한 담보물이 금전인 경우에 유가증권으로 담보물을 변경하는 것은 원칙적으로 법원의 재량에 속하지만, 담보물변경 결정으로 인하여 담보권리자의 이익이나 권리가 침해되지 않도록 원래의 공탁물에 상당한 합리적인 범위 내에서 결정하여야 한다. 따라서 공탁할 유가증권은 담보로 하여야 할 성질상 환가가 용이하지 아니하거나 시세의 변동이 심하여 안정성이 없는 것(예컨대 담보제공자 발행의 당좌수표)은 부적당하다(대법원 2000. 5. 31. 자 2000그22 결정).

담보물변경신청서에는 1,000원의 인지를 붙여야 하고, 신청사건(사건부호 ‘카담’)으로 전산입력한다.

담보물변경신청을 기각한 결정에 대해서는 즉시항고나 통상항고가 허용되지 않고 특별항고(민소 449조)로만 불복할 수 있다(대법원 2014. 1. 3. 자 2013마2042 결정).

○○ 지방법원

제○부

결 정

사 건 20○○카담○○ 담보물변경

신 청 인 ○○○

주소

피신청인 ○○○

주소

주 문

이 법원의 20 . . . 자 20○○카담○○ 결정 중 담보물 ‘별지 제1목록 기재 유가증권’을 ‘별지 제2목록 기재 유가증권’으로 변경한다.

이 유

신청인의 이 사건 담보물 변경신청은 이유 있으므로 주문과 같이 결정한다.

20○○. . .

재판장 판사 ○○○

판사 ○○○

판사 ○○○

## 제15장

---

# 소송구조

---

|     |               |     |
|-----|---------------|-----|
| 제1절 | 총 설           | 626 |
| 제2절 | 소송구조의 요건      | 627 |
| 제3절 | 소송구조의 신청 및 재판 | 634 |
| 제4절 | 소송구조의 효력      | 640 |
| 제5절 | 소송구조의 취소      | 645 |
| 제6절 | 변호사비용에 대한 구조  | 647 |
| 제7절 | 비용의 납입 및 추심   | 653 |

## 제1절 총 설

‘소송구조’란 소송비용을 지출할 자금능력이 부족한 사람을 위하여 국가가 구조조치를 취함으로써 직접적으로는 헌법 27조가 규정한 국민의 ‘재판받을 권리’와 헌법 11조가 규정한 법 앞의 평등을 실질적으로 보장하고, 이를 통하여 헌법 34조가 규정한 ‘인간다운 생활을 할 권리’ 및 생활능력이 없는 국민의 ‘국가의 보호를 받을 권리’를 보장해 주기 위하여 인정된 소송법상의 제도이다. 민사소송법은 128조 내지 133조에서 소송구조의 요건과 절차를 규정하고 있고, 민사소송규칙 24조 내지 27조에서 구체적인 사항을 정하고 있으며, ‘소송구조제도의 운영에 관한 예규’에서 소송구조의 사무처리 및 운영 등에 관하여 구체적인 기준·절차 등을 정하고 있다.

민사소송의 본안사건이 기본적인 소송구조의 대상이고, 가압류·가처분절차, 독촉절차 및 강제집행사건도 모두 구조대상이 된다. 행정사건 및 가사사건은 각 민사소송법이 준용되므로(행소 8조 2항, 가소 12조) 소송구조의 대상이 되지만, 비송사건은 소송사건과 그 목적 및 절차구조를 달리하며 비송사건절차법에서 민사소송법상 소송구조에 관한 규정을 준용하지 않고 있으므로 소송구조 대상이 아니며(대법원 2009. 9. 10. 자 2009스89 결정), 민사조정법은 조정에 관하여는 특별한 규정이 없는 한 비송사건절차법을 준용하도록 하면서(민조 39조) 달리 소송구조에 관한 규정을 준용하지 않고 있으므로 조정사건도 소송구조의 대상에서 제외된다. 소제기 전의 증거보전절차에 관하여는 견해의 대립이 있으나 적극적으로 해석함이 옳을 것이다.

## 제2절 소송구조의 요건

### 1. 무자력 요건

#### 가. 의 의

소송구조를 받기 위해서는 ‘소송비용을 지출할 자금능력이 부족한 사람’이어야 한다(민소 128조 1항 본문).

소송구조 요건으로서의 무자력은 국민기초생활보장법에 의한 수급권자나 이에 준하는 빈곤자 등에 한정되는 것이 아니라, 신청인의 자금능력과 예상되는 소송비용액과의 상관관계에 따라 판단되는 것으로서, 소송구조제도상의 고유한 개념이다. ‘소송구조제도의 운영에 관한 예규’ 3조의2는 ① 국민기초생활 보장법에 따른 수급자 및 차상위계층, ② 한부모가족지원법에 따른 지원대상자, ③ 기초연금법에 따른 기초연금 수급자, ④ 장애인연금법에 따른 수급자, ⑤ 북한이탈주민의 보호 및 정착지원에 관한 법률에 따른 보호대상자의 경우에는 자금능력이 부족한 것으로 보고 다른 요건의 심사만으로 소송구조 여부를 결정할 수 있도록 규정하고 있다.

자연인의 경우 경제적으로 빈곤하여 자기와 같이 사는 가족에게 필요한 생활을 해하지 않고서는 소송비용을 지출하기에 부족한 사람을 의미한다. 법인 그 밖의 단체의 경우는 소송비용을 지출함에 따라 그 목적사업의 수행이 저해되는 경우(소송수행을 위하여 필요한 자금의 조달이 곤란하여, 피용자의 급여를 지급할 수 없는 경우 등)를 의미한다.

#### 나. 지출이 예상되는 소송비용

민사소송법 128조의 소송비용을 같은 법 129조 1항 각 호에 규정된 소송비용으로 한정해야 한다는 견해도 있으나, 같은 법 129조 1항 각 호 소정의 소송비용 등은 물론이고, 민사소송비용법에 정해진 엄격한 의미의 소송비용

뿐만 아니라 당사자가 소송을 수행하기 위하여 소제기 전 또는 소송계속 중에 지출하는 필요비를 모두 포함한다고 보는 무한정설이 다수설이다.

무한정설에 의하면 지출이 예상되는 소송비용에는 ① 인지액, 송달료, 증인·감정인 등에 지급할 여비·일당 등 재판비용, ② 소송제기 준비를 위한 조사연구비, 교통비, 서류작성비·복사비 등의 비용 가운데 권리의 확장 또는 방어에 필요한 한도의 당사자비용, ③ 당사자가 선임한 변호사에게 지급할 비용 또는 보수 등을 포함하여 지출이 예상되는 소송비용을 판단하게 된다.

## 다. 신청인의 자금능력

### (1) 자산에 대한 평가방법

신청인이 얻고 있는 수입은 물론이고, 보유하고 있는 자산도 그의 자금능력을 판단하는 유력한 자료가 될 수 있다. 신청인의 생활의 기초가 되는 자산의 평가는 다음과 같은 점을 고려하여 한다.

농지, 기계, 소매점포 등 생계수단인 자산은 객관적으로는 교환가치를 가지지만 이러한 자산을 매각하는 것은 신청인으로부터 생산수단을 박탈하는 결과가 될 것이다. 이러한 사정은 가족들과 함께 거주하고 있는 가옥 등의 경우도 마찬가지이다. 따라서 위와 같은 자산을 보유하고 있는 경우에 그 자산의 보유사실만으로 곧바로 무자력 요건에 해당되지 않는다고 단정하는 것은 곤란하다.

가집행에 의하여 변제받은 금전은 장차 부당이득으로서 반환될 가능성이 있다고 하더라도, 재판절차에 의한 권리의 실현으로서 받게 된 것인 이상 처분 가능한 자산에 포함된다. 다만 그 금전이 치료비 등 피해회복에 소비될 것이 예상되는 때에는 자산에 가산하기 곤란할 것이다.

당해 소송을 제기하게 된 원인사실이 신청인의 생활에 미치고 있는 사정도 고려하여야 한다. 즉 불법행위에 기해 입은 피해회복을 위하여 비용이 지출되고 있을 때에는 무자력 판단에서 그 사정을 고려하여야 한다. 또한 자동

차사고에 따라 세대주가 사망하거나 중상을 입어 생활능력을 잃은 경우, 치료비로 상당한 비용이 지출되고 있는 경우, 손해배상의 일부를 지급받은 경우 등 당해 사고나 불법행위가 신청인의 생활에 미치는 영향을 고려할 필요가 있다.

## (2) 생계를 같이 하는 가족의 자금능력

소송구조는 자기 또는 가족의 생활을 해치게 되는 경우에 인정되므로, 생계를 같이하는 가족의 자금능력도 신청인의 생계에 기여 내지 부담으로 되는 범위에서는 이를 고려하여야 한다는 것이 다수설이며 일반적인 실무의 경향이다.

미성년자의 경우에는 본인은 대부분 소송비용을 지급할 자금능력이 없을 것이므로, 부양의무를 지고 있는 부모 등 근친자의 자금능력을 고려하여야 하는지가 문제 된다. 적극설은 부양의무를 지고 있는 부모 등이 충분한 자금능력을 가지고 있고(객관적 요건), 동시에 소송비용을 지급할 의사가 있다고(주관적 요건) 인정되는 경우에는 미성년자인 구조신청인의 무자력 요건이 부정된다고 한다. 신청인인 미성년자가 부모와 동거하고 있고, 부모가 상당한 자산과 수입을 보유하고 있는 때에는 그 사정을 고려하는 것이 현실에 부합한다는 것이다. 이에 대하여 소극설은 자녀가 부모에 대하여 부양의무의 이행으로서 소송비용의 지급을 청구할 수 없으므로, 부모의 자금능력은 원칙적으로 참작할 것이 아니라고 한다. 다만 부모가 적극적으로 비용부담을 하는 경우에는 그 사정을 참작할 수 있다고 한다.

배우자의 경우에는 부부의 자금능력을 함께 고려하는 것이 타당하다. 부부별산제가 채택되어 부의 재산과 처의 재산은 법률상 구별되고 있지만, 다른 한편으로 부부간에는 부양 및 협조의무가 인정되고 있으며(민법 826조), 무엇보다도 소송구조에서 무자력 요건은 신청인의 실제 생활 형편을 직시하여 상식적이고 보편적인 판단이 이루어져야 할 것이기 때문이다. 다만 부부가 별거를 하고 있는 경우, 이혼소송의 경우 등 특수한 사정이 있는 때에는



배우자의 자금능력을 고려하여서는 아니 될 것이다.

그 밖의 친족의 경우에는 친족간의 부양의무(민법 974조)를 근거로 그 자금능력을 고려하는 것은 현재의 사회실정에 비추어 합당하지 않다.

### (3) 제3자 소송담당의 경우 등

파산관재인, 회생채무자의 관리인, 유언집행자 등이 소송당사자가 되는 경우에는, 배후에 있는 파산재단·회생채무자나 이해관계인의 자금능력을 기준으로 판단하여야 하고, 형식상의 당사자 자신의 고유한 재산을 기준으로 판단하여서는 안 될 것이다. 또한 선정당사자의 경우 선정자의 자력을 고려하여 판단할 것이다. 한편 소송구조는 이를 받은 사람에게만 효력이 미치는 것이므로(민소 130조 1항) 여러 선정자가 그중의 여러 사람을 선정당사자로 선정하고 그 선정당사자가 소송구조를 신청한 경우에 있어서는, 그 선정당사자와 선정자와의 관계를 밝히고 어느 선정자에 대하여 어느 범위에서 소송구조를 하는 것인지를 명백히 하여야 한다(대법원 2003. 5. 23. 자 2003마 89 결정).

반면 타인을 위해 소송을 수행함과 동시에 자기의 이익보호를 위해서도 하는 경우(채권자대위소송, 추심소송, 주주의 대표소송 등)에 있어서는 신청인의 자금능력을 기준으로 판단하여야 한다.

### 라. 구체적 판단 기준

앞에서 본 바와 같이 무자력 요건은 구체적인 사건에서 신청인의 자금능력과 지출이 예상되는 소송비용을 비교하여 결정하는 것이 원칙이지만, 실무상으로는 소송구조의 복지적 기능, 사회적 형평성의 요청, 한정된 예산의 효율적 활용이라는 측면과 자금능력 판단의 통일성과 신속성에 비추어 볼 때 소송비용을 부담할 수 있는 자금능력 기준을 설정하고 이를 토대로 일정한 계층에 대하여 구조부여에 있어서 우선권을 부여하는 방식으로 운영함이 타당하다.

이러한 점을 감안하여 소송구조신청서에 첨부하는 소송구조 재산관계진술서[전산양식 A1331]에서도 신청인이 국민기초생활 보장법상의 수급권자인지 여부를 밝히도록 하고 있는데, 위 법의 수급권자는 절대적 무자력자로 판단하여 별도로 신청인의 자금능력과 지출이 예상되는 소송비용을 비교하지 않고 구조결정을 함이 타당하다.

#### 마. 개인파산·개인회생 사건

개인파산·면책 및 개인회생 사건에서 법원은 다음 중 어느 하나에 해당하는 사람의 신청 또는 직권으로 변호사비용 및 송달료에 한하여 소송구조를 할 수 있다(소송구조예규 22조 1항). 개인파산·면책 사건에서 법원은 다음 중 어느 하나에 해당하는 경우 파산관재인 선임에 관한 비용에 관하여 소송구조를 할 수 있다(2항).

- ① 국민기초생활 보장법에 따른 수급자
- ② 국민기초생활 보장법에서 정한 기준 중위소득의 100분의 75 이하 소득자임을 소명하는 자
- ③ 한부모가족지원법에 따른 지원대상자
- ④ 60세 이상인 자
- ⑤ 장애인복지법에 따른 장애인
- ⑥ 국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률 및 보훈보상대상자 지원에 관한 법률에 따른 상이등급 판정자, 고엽제후유의증 등 환자지원 및 단체설립에 관한 법률에 따른 장애등급 판정자, 5·18민주유공자 예우 및 단체설립에 관한 법률에 따른 장해등급 판정자

소송구조 지정변호사에게 지급할 기본보수액과 그 지급시기는 ① 개인파산·면책신청 사건의 경우 24만 원과 면책 여부 결정시, ② 개인회생신청 사건의 경우 42만 원과 변제계획 인가 여부 결정시이다(소송구조예규 25조 1항). 파산관재인 선임 비용은 30만 원을 상한으로 하고, 파산관재인 보수결

정시 지급한다(26조 1항).

## 2. 패소할 것이 분명한 경우가 아닐 것

민사소송법 128조 1항 단서는 “다만 패소할 것이 분명한 경우에는 그러하지 아니하다.”라고 규정하고 있다. 이 요건은 구조제도를 이용하여 남소가 이루어지는 것을 방지하기 위한 것으로 헌법에 위반되지 아니한다(헌법재판소 2001. 2. 22. 선고 99헌바74 결정). 신청인의 소송이 분명히 패소할 것으로 예측되는 때에 구조를 부여하는 것은, 소송에 필요한 비용을 허비하는 것일 뿐 아니라 상대방에게도 무익한 시간과 경비의 소비를 강요하는 결과가 되기 때문이다.

여기서 ‘패소할 것이 분명하지 않다’는 것은 소극적 요건이므로 신청인이 승소의 가능성을 적극적으로 진술하고 소명하여야 하는 것은 아니고 법원이 당시까지의 재판절차에서 나온 자료를 기초로 패소할 것이 분명하다고 판단할 수 있는 경우가 아니라면 그 요건은 구비되었다고 보아야 한다(대법원 2001. 6. 9. 자 2001마1044 결정). 반면, 주장 자체에서 이유가 없거나 공서양속에 반하는 경우, 주장사실이 분명히 허위라고 인정되는 경우, 남소임이 분명한 경우 등에는 이 요건을 갖추지 못한 것으로 해석할 수 있다.

다액의 청구 중 극히 일부만이 승소가능성이 있고 대부분이 패소할 것이 분명한 경우에는, 승소가능성이 있는 일부에 대하여 구조를 부여하기보다는, 소송을 전제로 보아 구조요건이 갖추어지지 아니한 것으로 취급하여 전부에 대하여 기각하는 것이 타당하다. 예컨대 손해배상사건에서 터무니없이 많은 금액을 청구하면서 그 인지액에 대하여 소송구조를 신청하는 경우 일부 인용될 것으로 보이는 금액에 해당하는 인지액에 대해서만 소송구조를 하는 것은 절차의 명확화 내지 부당한 제소방지를 위한 인지제도의 목적에 비추어 바람직하지 않으므로 전부에 대하여 기각함이 타당하다.

항소심은 속심이므로 제1심에서 패소하였다는 사실만으로 항소심에서도

패소할 것이 분명하다고 추정되는 것은 아니어서 제1심에서 패소한 당사자가 항소심에서 소송구조를 신청하는 경우에도 신청인이 적극적으로 항소심에서 승소할 가능성을 진술하고 소명하여야 하는 것은 아니고 법원은 신청인의 신청이유와 소명자료는 물론 본안소송에서의 소송자료 및 증거자료도 함께 종합하여 항소심에서 신청인이 패소할 것이 확실한지를 판단하여야 한다(대법원 2001. 6. 9. 자 2001마1044 결정).

상고심은 법률심이므로 그 특성상 항소심에서 패소한 당사자가 상고심에서 소송구조를 신청한 경우 제1심이나 항소심에서 소송구조를 신청하는 경우에 비하여 조금 더 구체적인 소명을 필요로 하고, 항소심 판결에 법률상의 하자 등이 있어 그 판결이 취소될 개연성이 없지 않다는 점 등을 구체적으로 명시하여 그 사유를 소명하여야 한다(대법원 2001. 3. 8. 자 2001카기38 결정).

재심의 경우, 새로이 발견한 증거에 의하면 재심의 소가 패소할 것이 분명하지 않을 때에는 구조신청을 기각하지 못한다고 보는 것이 타당하다.

강제집행사건에서는 '집행의 목적을 달성할 가능성이 없음이 분명하지 아니할 것'이 구조의 요건이 된다. 예컨대 부동산경매절차에서 잉여 가능성이 없을 것이 예상될 경우에는 '집행의 목적을 달성할 가능성이 없는 경우'에 해당될 것이다.

양쪽 당사자로부터 각기 구조신청이 있는 경우, 각 당사자에 대해 별도로 구조요건을 판단하여야 한다. 한쪽에 소송구조를 하였더라도 상대방이 패소할 가능성이 분명한 경우라고 판단한 것은 아니므로, 상대방의 구조신청이 당연히 요건을 갖추지 못한 것이라고 하여 기각할 수는 없다. 양쪽에 모두 소송구조를 하는 것을 법률이 금지하는 것은 아니므로, 사안에 따라서 양쪽 당사자 모두에게 소송구조를 하는 것이 타당한 경우도 있을 수 있다.

### 3. 구조요건의 소명

구조요건은 신청인이 소명하여야 한다(민소 128조 3항).

무자력 요건의 소명 방법으로는 신청인 및 그와 동거하는 가족의 자금능력을 적은 서면을 제출하여야 한다(민소규 24조 2항). 위와 같은 자금능력에 대한 서면의 제출은 신청인이 소송비용을 지출할 자금능력이 부족한 사람이라는 점을 소명하기 위한 하나의 방법으로 예시된 것이고, 신청인은 다른 방법으로 자금능력의 부족에 대한 소명을 하는 것도 가능하고, 법원은 자유심증에 따라 그 소명 여부를 판단하여야 한다(대법원 2021. 5. 27. 자 2021스 576 결정). 실무상 법원 창구에 비치된 소송구조 재산관계진술서[전산양식 A1331]를 작성하여 첨부서면과 함께 제출하는 형태로 운영한다. 소송구조의 성질상 보증금의 공탁에 의한 소명(민소 299조 2항)은 허용되지 아니한다.

모든 구조신청사건에 대하여 부동산·예금 등 자산의 미보유사실을 확인하는 것은 업무의 가중 및 절차의 지연으로 부적절하다. 그러나 구조요건의 심리단계에서 확인할 필요가 있다고 인정하는 때에는 재판장은 관련기관에 사실조회를 하는 방법으로 구조신청인의 자산보유 여부를 심리할 수 있다.

승소가능성 요건은 적극적으로 소명이 요구되는 것은 아니지만 결과적으로 이 요건이 갖추어지지 않았다고 인정되면 신청이 받아들여지지 않게 되므로 이러한 의미에서 신청인에게 소명책임이 있다고 할 수 있다. 소명자료는 소장·답변서 및 준비서면과 각종 증거 사본 등이 될 것이다.

## 제3절 소송구조의 신청 및 재판

### 1. 신청인

소송을 제기하려는 사람과 소송계속 중의 당사자는 소송구조를 신청할 수 있다. 소송계속 중의 당사자에는 원고·피고·참가인·소송승계인 등이 포함

된다. 외국인도 소송구조의 요건을 구비하면 소송구조를 받을 수 있고(소송구조예규 3조 3항), 법인도 공법인·사법인, 영리법인·비영리법인을 구분하지 않고 소송구조가 허용된다. 제3자의 소송담당에 의하여 소송당사자가 되는 자도 소송구조를 신청할 수 있다.

## 2. 관 할

소송구조에 대한 재판은 소송기록을 보관하고 있는 법원이 한다(민소 128조 4항). 따라서 소제기 전에는 소를 제기하려는 법원, 소제기 후에는 수소법원이 관할법원이며, 가압류·가처분 신청에 대한 구조신청은 목적물의 소재지를 관할하는 지방법원이나 본안의 관할법원, 강제집행에 대한 구조신청은 집행법원이 관할법원이 된다.

원심법원에 상소장 제출과 동시에 또는 상소제기 후 소송기록 송부 전에 구조신청을 하는 경우, 소송기록이 있는 원심법원이 관할법원이 되는데, 신속한 소송구조를 촉진함과 동시에 소송구조를 악용하는 것을 막기 위한 것이다.

단독사건으로 소송계속 중 사물관할의 변동을 가져오는 소변경 신청을 하면서 소송구조 신청을 한 경우 이송 전의 단독판사가 관할한다(대법원 1997. 12. 26. 자 97마1706 결정).

## 3. 신청 방식

구조신청은 서면으로 하여야 하고, 그 신청서에는 신청인 및 그와 같이 사는 가족의 자금능력을 적은 서면을 붙여야 한다(민소 128조 5항, 민소규 24조).

소송구조제도 활성화를 위해서 각급 법원은 소송비용을 지출할 자금능력이 부족할 때(다만 패소할 것이 분명한 때에는 제외)에는 소송구조를 받을 수 있다는 취지의 소송구조안내문[전산양식 A1343], 소송구조신청서[전산양식 A1330] 및 소송구조 재산관계진술서[전산양식 A1331]를 그 기재례와 함께 민원 접수창

구에 비치하여야 하는데(소송구조예규 2조 1항), 실무상 신청인이 각급 법원에 비치된 위와 같은 양식의 소송구조신청서에 원하는 소송구조 범위를 명시하는 등 이를 작성하고, 사건 내용은 소장 사본의 기재로 같음하며, 자금 능력에 관하여는 위와 같이 비치된 기재례를 참조하여 재산관계진술서를 작성하여 이를 제출하고 있다.

신청인은 신청서에 1,000원의 인지를 붙이고(인지액·편철방법예규), 송달료는 신청인 1인당 2회분을 예납하며(송달료예규 7조 1항, 별표1), 법원사무관 등은 위와 같이 작성된 신청서가 접수되면 민사신청사건으로 전산입력하고 사건번호(‘카구’)와 사건명(‘소송구조’)을 부여하여 기록을 편성(조제)한 뒤에 본안기록에 첨철(별책연결)한다.

#### 4. 소송구조의 재판

##### 가. 소송구조결정

구조결정은 당사자의 신청에 따라 또는 직권으로 할 수 있다(민소 128조 1항). 법원이 당사자에게 민사소송법 144조 2항의 규정에 따라 변호사의 선임을 명하거나, 당사자가 법정에서 소송비용의 부담이 과중함을 호소하는 등 실무처리 중 소송구조제도의 이용이 적합하다고 판단되는 경우에는, 재판부는 그 당사자에게 소송구조를 신청하게 하거나 직권으로 소송구조를 하여, 자금능력이 부족한 당사자의 재판을 받을 권리가 실질적으로 보장되도록 노력하여야 한다(소송구조예규 2조 2항).

소송구조의 신청이 적법하고 이유 있는 때에는 소송구조결정[전산양식 A1332, A1333]을 한다. 일부 구조결정을 하는 때에는 구조결정의 범위를 명확하게 기재하여야 하고, 결정 주문 예시는 다음과 같다(소송구조예규 3조 1항). 신청 중 일부에 대하여만 구조결정을 할 경우에는 나머지 신청을 기각하는 주문을 추가한다.

- ① 이 법원 20○○가합○○ 손해배상청구 사건에 관하여, 신청인에게 소장의 인지액에 대하여 소송구조를 한다.
- ② 이 법원 20○○가합○○ 소유권이전등기청구 사건에 관하여, 신청인에게 변호사비용에 대하여 소송구조를 한다.
- ③ 이 법원 20○○가합○○ 손해배상청구 사건에 관하여, 신청인에게 건물 시가감정의 감정료에 대하여 소송구조를 한다.

구조결정은 신청인에게 상당한 방법으로 고지한다. 구조결정을 상대방에 대하여도 고지할 것인지는 상대방에게 구조결정에 대한 즉시항고권을 인정할 것인지 여부에 의하여 결정된다. 소송구조를 하는 결정 중에서 상대방은 소송비용 담보면제의 구조결정에 대하여서만 불복할 수 있으므로(민소 133조 단서), 소송비용 담보면제의 구조가 포함된 경우에만 상대방에게 고지하면 될 것이다.

고지의 방법은 일반적인 결정·명령의 고지방식에 따라 타당하다고 인정하는 방법으로 하면 되지만, 즉시항고기간의 기산점을 명확하게 한다는 점을 고려할 때 송달의 방법으로 고지하는 것이 타당하다. 법원사무관등은 소송구조를 받은 당사자에게 소송구조결정에 따른 소송구조안내문[전산양식 A1343]을 송부 또는 교부하여야 하므로(소송구조예규 3조 2항), 결정등본을 작성하여 안내문과 함께 당사자에게 교부하거나 우편으로 송달하면 될 것이다.

소송구조 결정이 있는 때에는 법원사무관등은 소송기록 표지의 해당 당사자표시란에 “소송구조(소장인지액)”, “소송구조(변호사비용)”, “소송구조(전부)”와 같이 구조결정의 범위에 따라 소송구조사실을 적어야 하고, 변호사비용에 대하여 소송구조결정이 있는 때에는 소송기록표지의 대리인 표시란과 조서 및 판결서에 “변호사 ○○○(소송구조)”라고 적는다(소송구조예규 4조 1항, 2항).

## 나. 신청기각결정

구조신청이 이유 없는 때에는 소송구조신청 기각결정[전산양식 A1335]을



한다. 구조신청 기각결정도 결정의 일반원칙에 따라 이유를 생략할 수 있을 것이나 신청인 및 항고법원의 입장을 고려하면 신청을 기각하는 재판에 대하여는 원칙적으로 이유를 기재하는 것이 바람직하다. 신청기각결정은 신청인에게만 고지하면 된다.

소장에 인지를 첨부하지 않고 소송상 구조신청을 한 경우에, 비록 소송구조신청이 기각되었다고 하더라도, 민사소송법에서 정하고 있는 소송구조는 민사소송 등 인지법 1조에서 정하고 있는 인지를 붙임에 관한 예외 사유에 해당하며, 구조신청 기각결정에 대하여 즉시항고를 할 수 있으므로, 즉시항고기간 경과 등의 사유로 기각결정이 확정되기 전에는 인지첨부의무의 발생이 저지되어 인지첨부의무 이행이 정지·유예된다고 할 것이므로, 인지보정명령을 발하거나 인지 미보정을 이유로 소장을 각하할 수 없다(대법원 2008. 6. 2. 자 2007무77 결정). 소송구조신청 후 그에 대한 기각결정 확정 전에 발한 인지보정명령의 위법성은 소송구조신청 기각결정이 확정되더라도 치유되지 아니하므로, 소송구조신청 기각결정 확정 후에 그 인지보정명령에서 정한 보정기간이 경과하였다고 하더라도 이를 이유로 소장을 각하할 수 없고 다시 인지보정명령을 하여야 한다(대법원 2009. 5. 19. 자 2009마558 결정). 한편 소송구조신청이 있는 경우 인지첨부의무의 발생이 저지된다는 것은 소송구조신청을 기각하는 재판이 확정될 때까지 인지첨부의무의 이행이 정지 또는 유예되는 것을 의미하고, 소송구조신청이 있었다고 하여 종전에 이루어진 인지보정명령의 효력이 상실된다고 볼 근거는 없으므로, 종전의 인지보정명령에 따른 보정기간 중에 제기된 소송구조신청에 대하여 기각결정이 확정되면 재판장으로서 다시 인지보정명령을 할 필요는 없지만 종전의 인지보정명령에 따른 보정기간 전체가 다시 진행되어 그 기간이 경과한 때에 비로소 소장 등에 대한 각하명령을 할 수 있다(대법원 2008. 6. 2. 자 2007무77 결정).

2023. 4. 18. 신설된 민사소송법 128조 2항은 “패소할 것이 분명한 경우

(민소 128조 1항 단서) 소송구조 신청에 필요한 소송비용과 133조에 따른 불복신청에 필요한 소송비용에 대하여도 소송구조를 하지 않는다.”라고 규정하고 있다. 인지대와 송달료를 납부하지 않은 채 다수의 소장을 제출한 다음 법원의 인지보정명령에 대하여 소송구조 신청을 반복하여 제기하고, 소송구조신청 기각결정에 대하여 즉시항고나 재항고로 계속하여 불복하면서 소권을 남용하는 사례가 많았다. 이에 대응하여 위 신설조항은 위와 같이 소권을 남용하는 경우 소송구조 신청에 필요한 소송비용과 구조신청 기각결정에 대한 불복에 필요한 소송비용에 대하여 소송구조를 하지 않는다는 근거를 마련함으로써 소송구조 신청의 남용을 억제하려는 취지이다.

#### 다. 불 복

소송구조결정의 상대방은 소송비용의 담보면제 소송구조결정에 대하여만 즉시항고를 할 수 있다(민소 133조 단서). 위 즉시항고는 집행정지의 효력이 있으므로(447조) 법원은 피고의 담보제공 신청에 따라 원고에게 담보제공명령을 내릴 수 있다(117조).

소송구조신청을 기각하는 결정에 대하여 신청인은 즉시항고를 할 수 있다(민소 133조 본문). 이 경우 원심은 신청기록만 송부하면 되고, 항고법원이 심리에 필요한 경우 본안기록 중 필요부분의 등본 송부를 요구할 수 있으나(소송구조예규 5조), ‘패소할 것이 분명하다’는 이유로 기각된 경우에는 미리 본안기록의 등본을 송부함이 타당하다.

판결선고 후 상소기록 송부 전에 상소인이 한 상소장의 인지액을 포함하는 소송구조신청이 기각된 경우, 즉시항고가 제기되지 아니하여 소송구조신청 기각결정이 확정된 때에는 원심 재판장이 상소장에 대한 인지보정명령을 내리는 등 상소장 심사를 하여야 하고, 즉시항고가 제기된 때에는 원심 재판장은 민사소송법 399조 1항에 따른 보정명령을 하지 아니하고 바로 상소기록을 즉시항고기록과 함께 상소법원에 송부하게 하여야 한다(소송구조예규 6조).

## 제4절 소송구조의 효력

### 1. 객관적 범위

소송과 강제집행에 대한 소송구조의 범위는 민사소송법 129조 1항 각 호에 규정되어 있다. 다만 법원은 상당한 이유가 있는 때에는 다음 각 호 가운데 일부에 대한 소송구조를 할 수 있다(민소 129조 1항).

#### 가. 재판비용의 납입유예(1호)

소송비용은 당사자비용과 재판비용으로 구분되는데, 당사자가 법원에 내지 않고 스스로 지출하는 소송서류 작성비용, 소송서류 제출비용, 변론기일 출석에 소요되는 비용 등 당사자비용은 소송구조의 대상이 아니다.

‘재판비용’이라 함은 당사자가 소송을 수행하기 위하여 법원에 납입하여야 하는 비용으로 수수료(인지액)와 수수료 외의 비용(예납비용)이 있다. 수수료 외의 비용은 당사자가 법원에 미리 내야 하는 송달료, 공고비, 증인·감정인·통역인에게 지급하여야 하는 여비 및 숙박료, 일당, 감정료·통역료, 법관·법원공무원의 증거조사·사실의 조사에 필요한 여비·숙박료 등이다.

강제집행절차에 소요되는 집행비용도 재판비용에 포함되므로 그 성질에 따라 수수료 또는 수수료 외의 비용으로 처리한다.

법원으로부터 재판기록의 복사를 신청하고 복사물을 교부받기 위하여 부담하는 수수료(열람복사규 6조 2항 본문, 1장당 50원)는 소송비용(재판비용)에 포함되지 아니하는 것이므로[제13장(소송비용) 참조], 소송구조결정을 받더라도 그 납부를 유예받을 수 없다.

재판비용 중 수수료(인지액)는 소송구조결정을 받은 경우 그 납부가 유예되므로 국고대납절차가 필요 없으나, 수수료 외의 비용은 현실로 지출되어야 하므로 국고로부터 대납받아 지출하게 된다. 소송구조로 인한 국고대납

절차도 그 절차의 개시원인이 소송구조라는 점 및 법원사무관등이 국고대납 요청을 하여야 하는 것(민소규 25조 1항) 외에는 일반적인 국고대납절차와 다를 바가 없다. 국고대납절차에 대한 자세한 설명은 제13장(소송비용) 제3절 5. 참조.

#### 나. 변호사 및 집행관의 보수와 체당금의 지급유예(2호)

변호사의 '보수'란 변호사가 소송구조 결정에 따라 소송구조를 받을 사람을 위하여 소송을 수행한 대가를 말하고, 소송구조를 받을 사람의 상대방을 위한 변호사 보수까지 포함된다고 볼 수는 없다(대법원 2017. 4. 7. 선고 2016다251994 판결). 변호사의 '체당금'이란 소송구조 결정에 따라 소송구조를 받을 사람을 위한 소송수행을 위해 변호사가 먼저 지출하여 소요된 여비·숙박비 등의 비용을 말한다.

변호사비용에 대한 소송구조 결정을 받은 당사자는 변호사에게 지급해야 할 비용의 지급이 유예되므로, 변호사는 우선 자신의 비용으로 소송구조를 받은 당사자의 소송사무를 처리할 수밖에 없고, 당해 심급의 소송절차가 완료되면 국고에서 일정 금액의 보수를 받으며(민소 129조 2항), 소송구조를 받을 사람이 승소하여 그 상대방이 소송비용의 부담자로 정해지면 그 집행권원에 기하여 상대방으로부터 보수 및 비용의 전부 또는 일부를 상환받는다(132조 2항, 3항). 변호사비용구조에 관한 자세한 내용은 제6절 참조.

당사자가 집행관에게 송달 또는 강제집행의 신청을 하는 때에는 집행관법 및 집행관수수료규칙이 정하는 바에 따라 수수료 또는 체당금을 납부하여야 하는데(집행관법 19조 1항), 소송구조를 받은 당사자는 수수료 등을 납부할 필요가 없게 된다(집수규 25조 1항 단서). 집행관이 강제집행의 채무자로부터 그 수수료와 비용을 추심할 수 없으면 국고에서 집행관에게 상당한 금액을 지급한다(민소 129조 2항).

### 다. 소송비용의 담보면제(3호)

원고가 대한민국에 주소·사무소와 영업소를 두지 아니한 경우(민소 117조), 원고가 소송구조의 결정을 받으면 소송비용의 담보를 제공할 의무가 면제된다. 담보를 제공하도록 명하기 전에 구조결정이 있으면 담보제공명령을 할 수 없고, 담보제공명령이 먼저 내려진 후 구조결정이 있는 경우에는 담보를 제공할 의무가 없다. 소송비용 담보제공명령의 담보액에 대해 소송구조를 받기 위해서는 민사소송법 129조 1항 3호에서 정한 ‘소송비용의 담보면제’에 대한 소송구조결정을 받아야 한다(대법원 2017. 4. 7. 선고 2016다 251994 판결).

그러나 소송비용의 담보와 성질을 달리하는 가집행 선고시의 담보(민소 213조), 가압류·가처분 등의 담보(민집 280조, 301조)는 소송구조에 의하여 면제될 수 없다. 왜냐하면 그와 같은 경우의 담보는 그 구하는 행위가 직접 강제력을 행사하여 상대방 재산권에 대한 처분권을 제한하거나 재산권을 처분함으로써 상대방에게 생길 수 있는 손해를 담보하는 것이어서, 현실적으로 담보제공을 시키는 것이 원칙이기 때문이다.

### 라. 대법원규칙이 정하는 그 밖의 비용의 유예나 면제(4호)

국가의 예산이나 소송구조의 현실을 고려하여 위에 든 소송구조의 범위를 확장하여 소송구조를 현실화, 활성화할 수 있도록 대법원규칙에 의해 소송구조 효력의 객관적 범위를 정하도록 하였다. 따라서 소송비용 중 위 재판비용, 변호사 및 집행관의 보수와 체당금 외에 서기료, 제출비용 등과 같은 당사자 비용에 대하여도 대법원규칙을 정하여 그 지급을 유예하여 소송구조의 범위에 포함시킬 수 있으나, 현재 이에 대한 대법원규칙이 정해져 있지는 않다.

## 2. 주관적 범위

소송구조는 이를 받은 사람에게만 효력이 있다(민소 130조 1항). 즉 일신

전속적인 것이므로 일반승계·특정승계를 불문하고 소송승계인에 대하여는 그 효력이 미치지 않는다. 승계인도 자금능력이 부족한 경우에는 새로이 구조신청을 할 수밖에 없다. 다만 자금능력 부족의 판단 대상자가 아닌 자의 변경으로 인한 승계가 있는 경우, 즉 당사자의 법정대리인, 파산관재인, 수탁자 등의 자격 상실로 새로운 법정대리인, 파산관재인, 수탁자 등이 소송을 승계한 경우(235조 내지 237조)에는 현실적으로 소송을 담당하는 자가 변경되었다고 하더라도, 기본적인 소송의 실질은 동일하고 소송물의 실체법상의 주체는 변함이 없기 때문에, 종전에 부여된 소송구조의 효력은 그대로 지속된다. 구조신청 사건 계속 중 신청인이 사망하면 그 상속인에게 지위가 승계될 여지가 없고 구조신청 사건은 당연히 종료한다.

### 3. 시간적 범위(효력발생시기)

구조의 효력은 일반 원칙에 따라 구조결정이 고지된 때에 발생한다(민소 221조 1항). 그러나 구조결정에서 특별히 장래에 대하여서만 효력을 가진다고 명기하지 않은 이상 소장에 붙여야 하는 인지액은 신청 시에 소급하여 효력이 생긴다. 소의 제기와 동시에 인지액에 대하여 구조신청을 한 경우에는 소장에 붙일 인지액이 구조를 받아야 할 주요 부분이고 최초의 비용이 된다는 점에서 소제기 시에 소급하여 구조의 효력이 생기게 하는 것이 타당하기 때문이다.

효력이 소급되지 아니하는 경우에는 납입이 유예되는 재판비용 등은 결정 고지일 이후에 납입 또는 예납의무가 발생하는 것에 한정되며, 그 이전에 생긴 비용은 유예되지 아니한다.

### 4. 효력이 미치는 관련 절차의 범위

#### 가. 심급과 효력범위

소송구조의 결정은 당해 심급에 한하여 효력이 있다. 따라서 제1심에서

한 구조결정의 효력은 제1심에만 한정되고 제2심에는 미치지 않으며, 상소심에서 한 소송구조는 파기환송 또는 이송된 경우에 하급심에는 미치지 않는다. 반면에 독촉절차에서 한 구조의 효력은 이의신청 후의 제1심 소송절차에 미친다.

#### 나. 관련 절차와 효력범위

가압류·가처분사건에서 한 구조의 효력은 본안사건에 미치지 아니하고, 소의 추가적 또는 교환적 변경이나 반소의 제기가 있는 경우 종전의 소에 대한 구조의 효력이 미치지 아니한다. 그러나 제1심에서 구조한 사건이 다른 법원에 이송된 경우에는 구조의 효과는 이송받은 법원에까지 미친다고 할 것이다. 증거보전절차는 본안소송의 보조절차에 지나지 아니하고, 소송비용액 확정절차는 소송비용의 부담을 정하는 재판을 보충하므로, 각 본안에서 이루어진 소송구조의 효력이 미친다.

당사자참가에 대하여 응소하는 것은 별개의 사건이므로 종전의 구조결정의 효력이 미치지 아니하나, 보조참가에 대한 응소에는 그 효력이 미친다. 또 상소인에 대한 구조결정의 효력은 상대방의 부대상소에 대한 응소행위에도 미치나, 피상소인에 대한 구조의 효력은 그가 제기한 부대상소에는 미치지 아니한다.

#### 다. 강제집행절차와 효력범위

소송절차에서의 구조의 효력은 강제집행절차에 미치지 않는다. 이에 대하여 강제집행의 집행권원이 될 판결을 한 법원의 구조결정이 강제집행에 대하여도 그 효력이 미친다는 견해가 있다. 강제집행에 관한 소송구조는 집행권원이 성립한 후에 부여하는 것을 원칙으로 하여 개별적인 강제집행 목적물의 종류·가액과 예상되는 소요비용 등을 고려하여 결정하여야 할 것이다. 강제집행과 관련하여 제기된 각종 이의소송에 관하여는 따로 구조결정을 받

을 수밖에 없다.

## 제5절 소송구조의 취소

### 1. 취소의 사유와 시기

소송구조를 받은 사람이 소송비용을 납입할 자금능력이 있다는 것이 판명되거나, 자금능력이 있게 된 때에는 소송기록이 있는 법원은 언제든지 구조를 취소할 수 있다(민소 131조). 소송 진행 중 패소하게 될 것이 분명하게 되었더라도 소송구조제도의 취지상 소송구조 취소의 사유가 되지 못한다.

취소를 할 수 있는 시기는 소송완결 전이든 후이든 불문한다. 다만 구조결정을 한 대상사건의 절차가 판결의 확정, 그 밖의 사유로 종료된 뒤 5년이 지난 때에는 소송구조를 취소할 수 없다(민소규 27조 1항).

소송구조를 받은 사람이 자금능력이 있게 된 때에는 구조결정을 한 법원에 그 사실을 신고하여야 한다. 다만 위 기간이 경과한 때에는 그러하지 아니하다(민소규 27조 2항).

소송구조결정을 한 법원과 소송기록을 보관하고 있는 법원이 다른 경우에 구조결정을 한 법원이 구조를 받은 사람으로부터 자금능력회복 사실을 신고 받은 때에는 그 법원의 법원사무관등은 소송기록을 보관하고 있는 법원에 이를 통지하여야 하고, 신고인이 제출한 자금능력회복 사실 신고서 등을 덧붙여 보내야 한다(소송구조예규 7조).

### 2. 신청과 재판

#### 가. 신청과 접수

소송구조의 취소는 법원의 직권 또는 이해관계인의 신청에 의하여 가능하다(민소 131조). 여기에서 '이해관계인'에는 구조를 받은 사람의 상대방뿐만



이 아니라 보수 등을 지급받지 못한 변호사와 집행관 등이 모두 포함된다.

구조취소신청서에는 1,000원의 인지를 붙여야 한다. 신청서가 접수되면 사건번호(사건부호 ‘카구’)와 사건명(‘구조취소’)을 부여하고 민사신청사건으로 전산입력한다.

구조신청사건에 대하여 구조취소신청이 있는 경우에는 구조신청사건 기록에 합철하고, 취소사건에 부여한 사건번호와 사건명은 당초의 구조신청사건 기록 표지에 병기한다. 한편 직권구조사건에 대하여 구조취소신청이 있는 경우에는 취소사건 기록의 표지에 관련사건으로 본안사건번호를 기재하여 별책으로 관리하되, 본안기록에 첨철(별책연결)한다.

#### 나. 재 판

취소의 재판은 결정으로 행한다. 취소결정을 하는 경우에는 가능하면 소송구조를 받은 사람을 심문하는 것이 바람직하다. 취소결정의 이유는 자금능력이 부족하지 않게 된 사실을 구체적으로 설시한다. 구조취소의 결정만을 한 경우에는 장래에 향하여서만 효력이 있다.

구조취소의 결정만 하고 납입결정을 하지 아니한 경우에는 집행과 관련이 없으므로 결정등본을 송달하면 족하고, 구조취소와 함께 납입을 미루어둔 유예비용의 납입결정[전산양식 A1341]을 하는 경우에는 그 납입결정이 집행력 있는 집행권원의 효력을 가지므로(민소비용 12조 1항) 정본으로 송달하여야 한다. 직권으로 취소결정을 하는 때에는 그 결정의 송달비용은 국고에서 대납지급하고, 미루어 둔 비용의 지급을 명하는 금액에 포함시킨다. 구조취소 및 납입결정에 대하여는 즉시항고 할 수 있다(민소 133조).

취소신청이 이유 없다고 인정하는 때에는 신청의 기각결정[전산양식 A1342]을 한다. 신청기각의 재판에 대한 불복방법도 즉시항고라고 할 것이다.

법원사무관등은 소송이 계속하는 중에 구조취소결정이 있는 때에는 기록 표지에 적힌 “소송구조” 등 기재 부분을 주말(朱抹)하고, “구조취소”라고 적는

다(소송구조예규 4조 3항).

## 제6절 변호사비용에 대한 구조

### 1. 변호사비용의 구조결정

변호사비용에 대한 구조는 쟁점이 복잡하거나 당사자의 소송수행능력이 현저히 부족한 경우 또는 소송의 내용이 공익적 성격을 지니고 있는 경우에 소송수행과정에서 변호사의 조력이 필요한 사건을 대상으로 한다(대법원 2017. 4. 7. 선고 2016다251994 판결).

법원에서 변호사 선임명령(민소 144조 2항)을 내린 사건의 당사자, 최저임금 수준의 근로자 또는 국민기초생활 보장법상의 수급권자 등의 경우에는 우선순위를 부여할 수 있다.

### 2. 변호사 선임절차

#### 가. 선임 안내 및 지정

소송구조를 받은 당사자는 변호사 중 누구든지 소송구조 결정에 따른 지침을 알리고 승낙을 받아 그 변호사를 선임할 수 있으나, 당사자가 선임에 어려움을 겪게 될 가능성이 높고, 변호사 선임과정에 혼란이 발생할 수 있으므로 법원 또는 변호사단체의 개입에 의한 후원이 불가피하다. 그러나 법원이 변호사의 선임에 적극적으로 개입하는 것은 민사소송의 대립구조에 비추어 불필요한 오해나 불공정 시비를 불러일으킬 우려가 있으므로, 원칙적으로 대응 지방변호사회 또는 지회에서 소송구조 사건을 담당할 변호사의 선임안내 및 우선상담 변호사의 지정에 관한 사무를 관장하도록 하고, 변호사회가 위 사무를 관장할 수 없는 특별한 사정이 있는 경우에는 해당 법원에서 이를 담당한다(소송구조예규 8조).

변호사회에서 사무를 관장하는 경우, 법원사무관등은 구조를 받은 사람에게 대응 변호사회의 주소, 전화번호를 적은 소송구조안내문[전산양식 A1343]을 교부 또는 송부하고, 구조를 받은 사람이 직접 변호사회에 찾아가 당해 사건을 담당할 변호사를 안내 받도록 한다.

법원이 사무를 관장하는 경우, 법원장은 매년 연말까지 변호사회에서 소송구조사건의 선임을 희망하는 변호사 명단을 제출 받아 다음 해에 소송구조를 받은 사건을 담당할 변호사로 예정한 사람 및 지정순서를 일괄 등재한 명부를 작성하여야 하고, 법무법인·법무법인(유한)·법무조합 소속 변호사의 경우에는 그 변호사 개인을 지정한다. 지방법원 지원은 이를 참작하여 적절한 방법으로 명부를 작성한다. 명부에는 변호사의 이름, 사무실 주소, 전화번호, 팩스번호, 전자우편주소, 보수를 지급받을 수 있는 은행거래좌를 적어야 한다(소송구조예규 9조). 법원사무관등은 구조를 받은 사람에게 순번에 해당하는 변호사의 이름, 사무실 주소, 전화번호, 팩스번호 등을 적은 소송구조안내문[전산양식 A1343]을 교부 또는 송부한다.

#### 나. 선임절차

소송구조를 받은 사람과 상담한 변호사는 상담 결과에 따라 선임계약에 응하지 않을 수 있는데, 이러한 경우 소송구조를 받은 사람이 대한법률구조공단에 찾아가 선임을 의뢰하면 대한법률구조공단에서 수임하여 주는 것으로 위 공단 내부규정이 마련되어 있다.

변호사가 선임계약을 체결하는 경우 그 보수는 당사자와 협의하여 정할 수 있으나, 실무상 소송구조 안내문에서 ‘국고에서 소송구조 변호사에게 지급할 금액인 100만 원’(당해 사건 심급당, 소송구조예규 11조 1항)과 ‘변호사보수의 소송비용 산입에 관한 규칙’에 따라 상대방으로부터 추심할 수 있는 변호사보수를 고려하여 변호사보수를 약정하도록 안내하고 있다.

선임계약을 체결한 변호사는 위임장에 소송구조결정문 사본을 첨부하거나

“위임인에 대한 소송구조결정에 따라 위임계약을 체결합니다.”라는 문구를 기재한 위임장을 제출하여 소송구조로 인한 위임이라는 취지를 밝혀야 한다.

### 3. 변호사 보수와 체당금의 지급 또는 청구

구조결정에 따라 변호사 보수와 체당금의 지급이 유예되면 구조를 받은 사람은 변호사에게 보수와 체당금을 지급할 필요가 없다. 따라서 변호사는 의뢰인으로부터 보수를 지급받지 못하고 국고로부터 일정한 금액을 지급받게 된다. 다만 구조결정의 취소와 같은 사유가 발생하게 되면 변호사는 구조를 받은 당사자로부터 보수를 지급받을 수 있다. 아울러 구조를 받은 당사자의 상대방이 소송비용 부담의 재판을 받은 때에는 구조를 받은 당사자의 집행권원으로 상대방에 대하여 변호사 보수 및 체당금에 관한 비용액의 확정결정을 받아 강제집행을 할 수 있다.

#### 가. 국가의 지급

##### (1) 보수의 신청 및 보수액의 결정

국고에서 지급할 변호사 보수는 구조결정을 한 법원이 보수를 받을 변호사의 신청에 따라 그 심급의 소송절차가 완결된 때에 지급하며, 그 지급할 보수액은 변호사보수의 소송비용 산입에 관한 규칙을 참조하여 재판장의 감독하에 법원사무관등이 정한다(민소규 26조 1항, 2항). 법원사무관등은 보수액확정처분으로서 변호사 보수액 확인서[전산양식 A1345, A1345-1]를 작성한다(소송구조예규 12조 1항). 이 신청에는 보수계산서와 보수액을 소명하는데 필요한 서면을 제출하여야 한다(민소규 26조 3항, 민소 110조 2항).

변호사에게 지급할 기본보수액은 당해 사건의 심급마다 100만 원으로 한다(소송구조예규 11조 1항). 다만 이행권고결정, 지급명령, 자백 판결, 자백간주 판결 또는 무변론 판결로 완결된 사건에서 원고 또는 채권자의 소송대리인에게 지급할 기본보수액과 소송구조 변호사로 선임되었다가 해당 심급이

완결되기 전에 구조결정이 취소되거나 사임한 때 또는 해당 사건이 변론을 거치지 아니하고 종결된 경우에 그 변호사가 소송서류와 증거를 제출하는 등 상당한 변론준비 또는 변론활동을 한 경우에 한하여 해당 재판장의 재량으로 지급할 기본보수액은 위 금액의 2분의 1로 한다(2항). 당사자가 여러 명이거나 사건이 병합된 경우에도 하나의 사건으로 본다(3항).

법원사무관등은 소송목적의 값, 소송의 경과와 기간, 소송종결사유, 사건의 성질과 난이도, 당사자의 수, 소송구조 변호사가 들인 노력의 정도, 소송구조결정의 취소나 사임의 사유, 소송기록의 복사 등에 지출된 비용, 그 밖의 사정에 비추어 기본보수액을 증액하거나 감액할 필요가 있다고 인정하는 때에는 재판장의 허가를 받아 위 기본보수액의 1배 범위에서 증액하거나 기본보수액의 2분의 1 범위에서 감액할 수 있다(소송구조예규 11조의2).

## (2) 보수지급절차

변호사의 보수지급신청서에는 인지를 붙이지 않으며, 법원사무관등은 보수액확정처분[전산양식 A1345, A1345-1]을 마친 때에는 바로 보수지급의뢰서[전산양식 A1340]를 발행한다. 법원사무관등은 의뢰서에 당해 변호사의 연락처를 기재한 다음 명부에 당해 변호사의 은행거래계좌가 등재되어 있는 경우에는 의뢰서의 '계좌번호'란에 그 내용을 적어 소송구조결정을 한 법원의 회계담당공무원에게 교부하고, 명부에 당해 변호사의 은행거래계좌가 등재되어 있지 아니한 경우에는 전화 기타 적당한 방법으로 변호사에게 연락하여 계좌번호를 확인한 후 의뢰서의 '계좌번호'란에 그 계좌번호를 적어 회계담당공무원에게 교부한다. 회계담당공무원은 의뢰서에 기재된 변호사의 계좌로 지체 없이 보수를 입금하고, 전화, 팩시밀리 기타 적당한 방법으로 그 사실을 해당 변호사에게 통지하고, 지급담당자는 의뢰서 하단에 보수를 입금한 날짜를 기재하고 서명(기명) 날인한 후 의뢰서 원본을 보관하고, 사본 1부를 소송구조결정을 한 법원의 법원사무관에게 교부한다(소송구조예규 12조).

회계담당공무원으로부터 의뢰서 사본을 교부받은 법원사무관은 이를 소송

구조신청사건 기록에 편철한다. 다만 기록을 보관하고 있지 아니한 경우에는 보관하고 있는 기관에 의뢰서 사본을 추송하여 기록에 편철하도록 한다(소송구조예규 13조).

## 나. 소송구조가 취소된 경우

소송구조결정이 취소되면 소송구조로 인한 지급유예의 효력이 상실되므로 변호사는 구조를 받은 사람으로부터 보수 등을 지급받을 수 있다. 구조를 받은 사람이 임의로 보수를 지급하지 않는 경우 변호사는 통상의 소송에 의한 청구에 의하여 보수 및 채당금을 지급받아야 한다는 견해와 민사소송법 132조의 경우와 같이 비용의 지급을 명하는 결정을 받아 당사자에게 청구할 수 있다는 견해가 있다.

변호사가 지급받을 보수 및 채당금은 기본적으로 당사자 사이에 체결한 위임계약에 정한 바에 따른다. 다만 당해 심급이 완결되어 보수액확정결정에 의하여 국고로부터 보수를 지급받은 다음 소송구조결정이 취소된 경우에는 이미 국가로부터 지급받은 금액을 공제한다.

## 다. 상대방에 대한 추심

### (1) 총 설

변호사는 상대방이 소송비용 부담의 재판을 받은 경우 구조를 받은 사람의 집행권원으로 상대방에 대하여 보수와 채당금에 관한 비용액의 확정결정 신청과 강제집행을 할 수 있다(민소 132조 2항). 여기서 ‘소송비용 부담의 재판을 받은 때’라 함은, 확정판결에 의하여 소송비용을 부담하게 된 경우 또는 재판에 의하지 아니하고 소송이 완결된 경우뿐만 아니라 소송비용 부담의 재판에 가집행이 붙은 경우(110조 1항)도 포함된다.

이 경우 결정으로 확정될 변호사보수는 해당 변호사가 국가로부터 소송구조와 관련하여 받는 보수와는 상관없이 변호사보수의 소송비용 산입에 관한

규칙에 따라 계산한 금액 가운데 상대방이 부담할 부분이다. 다만 보수계약이 있는 경우에는 소송구조를 받은 사람이 보수계약에 의하여 지급할 보수액의 범위 내에서 위와 같은 방법으로 부담 부분이 정하여질 것이다.

변호사는 자기 이름으로 추심절차를 행하게 되며, 변호사의 추심권 범위에 속하는 소송비용에 대하여는 구조를 받은 당사자는 스스로 추심할 권리를 상실하게 되고, 상대방도 구조를 받은 당사자에게 변상하였다는 이유로 대항할 수 없게 된다. 따라서 변호사의 추심권의 범위에 속하는 소송비용에 대하여 소송구조를 받은 당사자가 소송비용액 확정결정신청을 한 경우 법원은 이를 각하하여야 한다. 아울러 구조를 받은 당사자는 위의 비용에 관하여 상대방에 대한 권리를 포기하거나 처분할 수 없다.

## (2) 추심방법

변호사보수 및 채당금의 추심방법은 소송완결사유에 따라 다르다.

소송이 재판에 의하여 종료된 경우에는 변호사는 소송구조를 받은 사람의 집행권원으로 비용부담의 재판을 받은 상대방에 대하여 스스로 비용액확정결정[전산양식 A1339]을 받은 후 강제집행할 수 있다(민소 132조 1항, 2항). 이 절차에 의한 비용액 확정결정에는 변호사가 고유의 자격에서 신청인이 되는 것이므로, 비용액 확정결정으로 집행함에 있어 승계집행문을 받을 필요가 없다.

화해에 의하여 소송비용이 소송구조를 받은 사람의 상대방이 부담하는 것으로 정해진 경우에는 변호사는 당사자를 대위하여 자신의 이름으로 소송비용액확정 신청을 할 수 있다(민소 132조 3항, 113조). 그 외에 소송이 재판 이외의 사유로 종료된 경우에는 변호사는 당사자를 대위하여 자신의 이름으로 소송비용의 부담 재판을 신청할 수 있다(민소 132조 3항, 114조).

## (3) 추심절차

변호사의 보수와 채당금에 관한 비용액의 확정결정신청서에는 1,000원의 인지를 붙여야 하며, 민사신청사건으로 전산입력하여 사건번호(사건부호 ‘카

기')를 부여하고 별책으로 기록을 편성하여야 한다(인지액·편철방법예규).

비용액 확정결정신청 사건은 판결·결정으로 소송비용의 부담이 행하여진 때에는 제1심 수소법원이 관할한다(민소 110조 1항). 상소심에서 부담의 재판이 변경된 경우에도 마찬가지이다. 화해로 비용부담자가 정해진 경우에도 이와 같으나, 소송이 화해 이외에 재판에 의하지 아니하고 완결된 경우에는 소송구조 변호사가 관여한 당해 소송이 완결될 당시의 소송계속법원이 관할한다(대법원 1992. 11. 30. 자 90마1003 결정 참조).

변호사의 보수와 체당금에 관한 비용액의 확정결정에 대하여는 즉시항고할 수 있다(민소 133조).

## 제7절 비용의 납입 및 추심

### 1. 납입결정

#### 가. 소송승계에 따른 납입결정

구조를 받은 사람의 소송승제인에 대하여는 구조결정의 효력이 미치지 아니하므로 소송구조를 받은 당사자가 사망하거나 법인이 합병으로 소멸하여 상속인 또는 존속법인이나 신설법인이 소송을 승계한 경우, 법원은 소송승제인에 대하여 납입을 미루어 두거나 국고에서 지급한 소송비용의 납입결정을 할 수 있다(민소 130조 2항). 여기에서의 소송승제인은 포괄승제인만을 가리킨다. 법원이 소송승제인에 대하여 피승제인에게 미루어 둔 비용을 납입하도록 명하는 재판은 수소법원이 직권으로 결정으로 하는데, 소송승제인이 유예된 소송비용을 지급할 자금능력을 갖는 때에 한하여 납입명령을 한다.

이 경우 법원은 별도로 구조취소결정을 할 필요는 없고, 금액을 정하여 결정[전산양식 A1337]으로써 납입을 명하는데, 납입을 명할 비용은 민사소송법 129조 1항 1호 소정의 비용을 말한다. 납입을 명하는 재판에 대하여



승계인은 즉시항고를 할 수 있다(민소 133조). 승계인에 대한 비용납입결정은 집행력 있는 집행권원과 동일한 효력을 가지며(민소비용 12조 1항), 집행문을 부여받지 않고 강제집행할 수 있다.

승계인에 대하여 납입을 명하는 재판기록은 별도의 기록으로 편성하지 아니하고, 구조신청사건 기록에 가철한다.

#### 나. 구조취소로 인한 납입결정

소송구조결정을 한 사건에 관하여 구조결정을 취소하는 경우 납입을 미루어 두거나 국고에서 지급한 소송비용의 지급을 명할 수 있다(민소 131조). 구조취소결과와 납입결정은 가분적이므로, 구조취소결정을 하는 경우 납입결정을 할 것인지 여부는 구조취소의 사유를 고려하여 법원이 결정한다. 예컨대 구조사유가 당초부터 존재하지 아니하였다거나, 기존에 유예된 비용까지 부담할 수 있는 자금능력을 갖게 되었다는 사유로 구조취소를 하는 때에는 납입결정을 하는 것이 타당하겠지만, 이에 해당하지 않는 때에는 구조가 취소되더라도 장래를 향하여 향후의 소송비용을 스스로 부담하는 데에 그치도록 하며 기존의 유예비용에 대한 납입결정을 할 필요가 없다. 구조취소와 함께 납입결정을 하는 경우의 양식은 [전산양식 A1341]과 같다.

이 재판은 소송기록을 보관하고 있는 법원이 행하고(민소 131조), 결정 중에서 지급하도록 명하는 유예비용의 구체적 금액을 명시하여야 한다. 납입결정은 집행력 있는 집행권원과 동일한 효력을 가지며(민소비용 12조 2항, 1항), 집행문을 부여받지 않고 강제집행할 수 있다.

납입을 명하는 재판에 대하여 구조를 받은 사람은 즉시항고를 할 수 있다(민소 133조).

납입결정에 관한 기록은 구조취소사건 기록에 가철한다. 직권으로 구조를 취소하면서 납입을 명하는 재판을 한 경우에는 별도의 구조취소사건 기록이 편성되지 않으므로 구조신청사건 기록에 가철한다.

## 2. 추심결정

소송구조를 받은 사람에게 납입을 유예한 비용은 그 소송비용 부담의 재판을 받은 상대방으로부터 직접 추심할 수 있다(민소 132조 1항). 소송구조를 받은 사람에게 납입을 미루어 두거나 국고에서 지급한 소송비용에 대하여 그 부담의 재판[확정판결에 의하여 소송이 완결된 경우, 소송비용의 재판에 가집행이 붙은 경우(110조 1항)]이 있는 경우 제1심 수소법원은 상대방으로부터 그 소송비용을 직접 추심할 수 있다(132조 1항). 소송구조를 받은 사람의 상대방이 소송비용 전부를 부담하는 재판이 확정되고 상대방으로부터 추심할 소송비용이 30만 원을 초과하는 때에는 제1심 수소법원은 상대방에 대한 소송비용의 추심결정을 하여야 한다(소송구조예규 17조 3호). 납입결정이 소송구조를 받은 자 또는 그 승계인에 대한 것임에 반하여, 추심결정은 비용 부담의 재판을 받은 상대방에 대한 것이다.

이러한 추심을 하기 위하여는 본안소송의 제1심 수소법원이 구조를 받은 사람에게 납입을 유예한 비용의 액을 명시하고, 그 비용의 액의 추심을 명하는 결정[전산양식 A1338]을 한 다음 그 정본을 양쪽 당사자에게 송달하여야 한다. 추심결정의 주문례는 “피고는 소송구조결정에 의하여 원고에게 납입을 유예한 별지 소송비용액 계산서 기재의 소송비용 ○원을 국가에 지급하라.”와 같다. 이 결정은 집행력 있는 집행권원과 동일한 효력을 가지므로(민소비용 12조 2항, 1항), 집행문을 부여받지 않고 강제집행할 수 있다. 이 결정에 대하여 상대방은 즉시항고로 불복할 수 있다(민소 133조). 항고심은 제1심법원의 추심결정이 법률에 따른 정당한 것인지 직권으로 살필 의무가 있다(대법원 2023. 7. 13. 자 2018마6041 결정).

소송구조를 받은 당사자와 상대방 당사자 사이에 소송비용을 일부씩 부담하는 판결이 선고된 경우, 소송구조로 납입 또는 지급이 유예된 재판비용이나 변호사보수도 소송구조를 받은 당사자가 지출하는 소송비용으로 산정하고 부담비율에 따라 각자 부담할 액을 정하여 대등액에서 상계한 결과 상대

방 당사자가 소송구조 당사자에게 지급할 차액이 존재하는 경우에 한하여, 국가도 상대방 당사자에게 그 차액 범위에서 소송구조에 따라 납입을 유예했거나 국고에서 지급된 비용의 추심결정을 할 수 있다(대법원 2023. 7. 13. 자 2018마6041 결정).

추심결정을 하는 경우 소송구조를 받은 사람과 그 상대방이 소송비용을 일부씩 부담하는 재판이 있는 때에는 위와 같이 법정상계(민소 112조)를 하기 위하여 제1심 수소법원은 양 당사자(필요하다고 인정하는 경우에는 소송구조 변호사를 포함한다)에게 소송비용계산서와 소명자료의 제출을 최고(전산양식 A1350)하여야 한다(소송구조예규 17조 2항).

국가의 직권에 의한 소송비용 부담자에 대한 추심결정(민소 132조 1항, 민소비용 12조)과 당사자 및 소송구조 변호사의 신청에 의한 비용액확정결정(민소 110조, 132조 2항, 3항)이 경합할 수 있다. 이 경우에는 국가·당사자 및 소송구조 변호사 사이의 추심 절차, 순위 및 방법과 관련하여 견해가 대립하지만, 유예비용 및 양쪽 당사자 사이에 생긴 모든 소송비용액을 합산한 후, 이를 대등한 금액에서 상계한 다음(112조), 상대방이 본래 납부의무자에 대하여 상환하여야 할 금액이 있는 때에는 국가가 우선하여 상대방으로부터 유예비용의 전액 또는 일부에 관하여 추심할 수 있다는 견해가 실무상 유력하다.

소송구조를 받은 사람이 강제집행의 채권자인 경우, 강제집행절차비용은 소송절차의 유예비용처럼 종국판결 등의 재판에 의해서 그 부담자가 정하여지는 것이 아니라, 민사집행법 53조 1항의 규정에 따라 채무자가 부담하게 되며, 그 집행절차에서 우선적으로 변상받게 된다. 따라서 국가는 민사소송비용법에 규정된 절차에 의하지 아니하고, 민사집행법의 규정에 따라 강제집행절차비용을 그 집행절차 내에서 바로 추심할 수 있다.

### 3. 국가채권발생통지 및 사후관리

#### 가. 국가채권발생통지

소송구조결정을 한 사건에 관하여 납입결정이나 추심결정이 있는 때에는 법원사무관등은 바로 국가채권발생통지서에 의하여 소속법원의 채권관리관에게 국가채권 관리법 11조의2의 규정에 의한 통지를 하여야 한다. 위 채권발생통지서에는 그 납입결정 또는 추심결정 정보와 송달증명서를 첨부하여야 한다.

채권관리관이 위와 같은 통지를 받은 때에는 국가채권 관리법, 같은 법 시행령·시행규칙이 정하는 바에 따라 납입고지, 독촉 등 국가채권의 관리에 관한 직무를 행하여야 한다. 다만 국가채권 관리법 15조에 규정된 강제이행의 청구는 같은 법 15조 2호의 규정에 의한 조치에 한한다(국고대납예규 16조).

#### 나. 당사자의 납부

당사자가 환수결정에 의하여 소송비용을 납부하는 때에는 법원사무관등의 확인을 얻어 당해 법원 또는 지원의 수입금출납공무원에게 납부하여야 한다. 위와 같이 소송비용을 납부받은 수입금출납공무원은 '국고금 관리법 시행규칙' 23조, 24조에 규정된 처리를 한 후 영수필통지서를 법원사무관등에게 송부하여야 하고, 법원사무관등은 이를 소송구조신청사건 기록에 편철하여야 한다. 수입징수관은 위와 같이 납부된 소송비용에 관하여 채권관리관에게 채권소멸의 통지[전산양식 A1306]를 하여야 한다(국고대납예규 17조).

#### 다. 강제이행의 청구

채권관리관은 독촉기한을 경과하여도 이행되지 아니한 채권이 있는 때에는 환수결정 정보와 송달증명서를 법원행정처장에게 제출하여야 한다. 법원행정처장이 국가채권 관리법 15조 2호에 규정에 의하여 강제집행을 요청할 때에는 환수결정 정보와 송달증명서를 법무부장관에게 송부하여야 한다(국고대납예규 22조).